中图分类号：_____ 密　　级：_____

UDC：_____ 本校编号：10652

西南政法大学

硕士学位论文

论文题目：论瑕疵出资股东的执行追加

研究生姓名：张思迪　　学　　号：20160301060476

校内指导教师姓名：丁宝同　　职　　称：副教授

校外指导教师姓名：_____　　职务职称：_____

申请学位等级：硕士　学科：法学　　专业：诉讼法学

论文提交日期：2019年3月14日　　论文答辩日期：_____

中国知网 https://www.cnki.net

硕 士 学 位 论 文

论瑕疵出资股东的执行追加

The Procedure of Adding Defective Shareholders as Parties of Execution

作 者 姓 名：张 思 迪

指 导 教 师：丁 宝 同

西 南 政 法 大 学

Southwest University of Political Science and Law

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

内容摘要

实践中，股东瑕疵出资的行为屡见不鲜、形式多样，尤其是在公司资本制度改革后，取消最低注册资本要求、法定缴纳出资期限的规定为股东瑕疵出资行为大开方便之门。在此情况下，公司常常成为“空壳”，如果仍严格遵循执行力相对性原则，债权人的胜诉判决往往会因公司资产的匮乏而成为一张白纸，即使债权人另行起诉股东，债权能否实现也会因诉讼以及执行中诸多不确定因素的影响而陷入不稳定，该情形势必导致社会公众对公权力解决纠纷效果的怀疑，进而使得人们重新寻求无序的私力救济。另一方面，近年来，法院在执行工作中，适当地突破执行力相对性原则，尤其是追加瑕疵出资股东为被执行人，要求其承担清偿责任，强有力地推动了各级法院的执行工作，在实践中成效卓越。

瑕疵出资股东的执行追加，对这一命题的研究，涉及实体规范与程序规范两个维度的内容，具体又可分解为瑕疵出资的认定、瑕疵出资的责任形态以及瑕疵出资股东的执行追加程序规范三个基本要素，这三个基本要素是确定瑕疵出资股东执行追加具体规则的关键所在。笔者以这三个要素的实体规范与程序规范的演变历程为出发点，分析其在实践中适用上的困难，在分别厘清其实体法理和程序法理的基础上，提出完善、优化相关执行当事人变更、追加程序细则的建议。

基于此，本文正文部分由四部分构成：

一、瑕疵出资股东执行追加制度的演变历程。该部分介绍了瑕疵出资责任的法律渊源演变的过程：从《公司法》到《公司法解释（三）》，责任形态从一般有限责任变迁为补充有限责任；从《执行规定（试行）》、《<民诉法>解释》到《变更、追加规定》，程序规则从代位执行变更为执行追加；《公司法》修法导致资本制度从资本实缴制转变为资本认缴制，资本信用理念向资产信用理念变迁，瑕疵出资的认定标准也应作相应调整。此部分内容是后述展开的基础，所以本文将以法律规范的具体条文为研究的切入点。

二、瑕疵出资股东执行追加程序的现实困境。制度在适用中遭遇现实困境直接源于法律渊源之间的重重矛盾，具体而言包含三个层面：第一，法理基础争议重重，包括程序法理上另诉审判救济与执行追加救济之争、针对到期债权的代位执行与基于瑕疵出资责任的执行追加之争、基于既判力扩张的执行力扩张与超越既判力扩张的执行力扩张之

中国知网 https://www.cnki.net

争，实体法理上一般有限责任形态与补充有限责任形态的争议；第二，规则适用矛盾重重，包括实体规则之间、程序规则之间以及程序规则与实体规则之间的矛盾；第三，程序操作困难重重，指的是司法解释规定的瑕疵出资股东的执行追加的具体程序规则存在诸多不完善之处，譬如在申请、审查、裁判以及救济程序上均存在问题亟待解决。

三、瑕疵出资股东执行追加制度的基本法理。本部分论述建立在前述理论争议的基础上，通过回应具体的争论，厘清瑕疵出资股东执行追加的法理基础。具言之，在程序法理上，首先论证执行追加程序具有正当性，进而阐明其法理基础为执行名义执行力主观范围的扩张，在此基础上，提出执行力扩张应与既判力扩张保持逻辑上的一致性，也就是执行力主观效力扩张的范围应与既判力扩张的三种类型基本一致，但基于执行程序与诉讼程序价值目标上的差异，应在既判力扩张三种类型的基础上作出相应调整，变更第三类“向争议标的物实际持有主体的扩张”为“向执行标的实际持有主体的扩张”，并提出瑕疵出资股东执行追加的执行力渊源为执行力主观范围“向执行标的实际持有主体扩张”。其次，在实体法理上，论述瑕疵出资的责任形态应回归公司法这一部门立法的一般有限责任的基本立场，并从补充性本身蕴含的逻辑悖论及适用上的困难局面等方面对补充责任形态展开批判。最后，从实体法秩序的维护和程序法效率价值的追求两方面来讨论瑕疵出资股东执行追加的制度价值。

四、瑕疵出资股东执行追加程序的完善建议。本部分是论题之归宿、文章价值之集中体现。本部分在前述现实困境与基本法理的基础上，对整套程序规则的完善提出一点拙见，并细化到申请程序、审查程序、裁判程序以及救济程序，对各环节存在的具体问题提出针对性的完善建议。

关键词：瑕疵出资；责任形态；执行追加；主观范围扩张；补充责任

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In practice, the behavior of shareholders' capital contribution flaw is not uncommon, and the forms are diverse. Especially after the reform of company capital system, the capital subscription system provides a strong shelter for the shareholders' defective capital contribution behavior. Under this circumstance, the company often becomes a “empty shell”. If the principle of relative force of the subjective of the executive force is still strictly adhered to, the creditor’s winning judgment will also become a blank sheet due to the lack of assets of the company. Even if the creditor separately sues the shareholders,the realization of creditor's rights will also become uncertain due to the influence of various factors in litigation and enforcement. This situation will inevitably lead to doubts about the effect of public power to resolve disputes, which will lead people to seek disorderly private relief. On the other hand, in recent years, the shareholders who do not contribution have been added as executive parties, demanding responsibility for liquidation,vigorously promoted the implementation of the courts at all levels and achieved good social effects.

The implementation of this proposition is related to two dimensions of the entity specification and the procedure specification, which can be decomposed into the identification of the defective capital contribution, the responsibility form of the capital contribution flaw, and the provisions of the procedure of adding the defective capital contribution shareholder as parties of execution. The three basic elements, which are the key to determining the specific rules for the implementation of the additional parties of execution.Based on the civil norms and procedural norms of these three elements, the author explores the difficulties in its application in practice. On the basis of clarifying the specific civil law and procedural law theory, the author put forward detailed recommendations for optimizing the procedure.

Based on this, the body of this paper is composed of four parts:

I. The evolution of the provisions of the procedure of adding shareholders as parties of execution. This part introduces the process of the evolution of the legal origin of the capital contribution responsibility: from the "Company Law" to the "Company Law Interpretation

中国知网 https://www.cnki.net

(III)", the responsibility form changes from the general limited liability to the secondary limited liability; from the "Implementation Regulations (Trial)", "Interpretation of the Civil Procedure Law" to "Changes and Adds Provisions", the procedural rules changed from subrogation to change or adds the parties of execution; the "Company Law" reform led to the transformation of the capital system from the capital payment system to the capital subscription system. The concept of capital credit changes to the concept of asset credit, and the criteria for the identification of effective capital contribution should also be changed accordingly. This part of the paper is the basis for the development described later, so this paper will take the specific provisions of the legal norms as the entry point for the study.

II. The actual dilemma of the implement of the procedure of adding shareholders who have failed to fulfill or to fully fulfill the obligation of capital contribute as parties.The practical dilemma applied by the system directly stems from the contradictions between the legal sources. Specifically, it contains three levels: First, the legal basis is very controversial, including dispute between the trial and the enforcement of adding parties,between the subrogation of the creditor's rights and the procedure of adding parties based on capital contribution responsibility,and dispute between the scope of the expansion of the executive force and the expansion of the res judicata.And the dispute between the general legal limited liability form and the secondary limited liability form.Second, there are many contradictions between rules. Third, the procedural operation is very difficult. It refers to the existence of many imperfections in the specific procedural rules imposed by the judicial interpretation of the execution of adding defective shareholders. For example, there are problems in the application procedure, the review procedure, the referee procedure and the relief procedure.

III. The basic legal principles for the procedure of adding defective shareholders.This part is based on the analysis of the legal sources and analysis of the dilemma of application, to clarify the basic legal basis for the procedure of adding defective shareholders. Specifically, in the procedural legal theory, firstly demonstrate the theoretical basis of the expansion of the enforcement force , and further propose that the subjective scope expansion of execution should be logically consistent with the subjective scope expansion of the res judicata.That is,

中国知网 https://www.cnki.net

the type of expansion of the subjective scope of execution should be basically the same as the three types of expansion of the res judicata, but based on the difference in the value objectives of the execution procedure and the trial, the corresponding adjustments are made on the basis of the three types of expansion.In the civil jurisprudence, the responsibility form of defective capital contribution should be returned to the basic position of the general limited liability of the legislation of the company law, and the secondary responsibility form should be criticized from the complementary logical paradox and the contradictory situation in application. Finally, from the maintenance of the order of the civil law and the pursuit of the efficiency value of the procedural law, the authors discuss the institutional value of this procedure.

IV. Suggestions for the procedures of adding defective shareholders.This part of the discussion is the end of the topic, the embodiment of the value of the article. Based on the above-mentioned realistic dilemmas and basic theories, this part proposes perfect suggestions for the specific problems and defects of the application procedures, review procedures, referee procedures and relief procedures.

Key word:defective capital contribution;form of liability;adding party of execution;expansion of the subjective scope of the executive force;secondary responsibility

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

引　言.....1

一、瑕疵出资股东执行追加制度的演变历程.....4

（一）从间接概括到直接具体：执行程序规则的演变.....4

（二）从一般有限到补充有限：瑕疵出资责任的演变.....10

（三）从资本实缴到资本认缴：资本缴纳制度的演变.....13

二、瑕疵出资股东执行追加程序的现实困境.....15

（一）法理基础争议重重.....16

（二）规则适用矛盾重重.....20

（三）程序操作问题重重.....26

三、瑕疵出资股东执行追加制度的基本法理.....30

（一）执行力的主观范围扩张.....30

（二）瑕疵出资的责任形态.....41

（三）执行追加的制度价值.....45

四、瑕疵出资股东执行追加程序的规则完善.....47

（一）申请程序的规则完善.....49

（二）审查程序的规则完善.....50

（三）裁判程序的规则完善.....52

（四）救济程序的规则完善.....56

参考文献.....59

致　谢.....64

中国知网　https://www.cnki.net

引　　言

（一）论题的研究目的及研究现状

1.论题的研究目的

强制执行是运用国家强制力，迫使债务人履行裁判文书等执行名义确定的执行债务，以实现债权人的实体权利，审判程序与执行程序构成司法救济的两道防线，其中执行程序为终局性的环节，审判与执行二者应各司其职、各负其责。[1]

2016 年出台的《关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》（以下简称《变更、追加规定》），其第 17～19 条规定债权人可以申请追加瑕疵出资的股东为被执行人，于对公司债务诉讼案件的执行中径直执行股东的财产，缘何可以不经审判程序直接于执行中对实体权利义务作出判定？关于该情形下执行追加的理论基础学界众说纷纭，且诸观点差异较大，因此有厘清其理论基础之必要。

又《公司法解释（三）》规定瑕疵出资股东对外生补充有限责任，该责任形态意味着股东在责任承担上具有顺位利益，该顺位利益在执行追加程序中如何实现？顺位利益在执行追加中的适用似乎在逻辑上存在无法自洽之处，且与其他执行规范具体规定存在难以兼容之处，因此有研究其程序规则之需要。

2. 论题的研究现状

关于瑕疵出资股东的责任认定。2013 年底公司资本制度改革取消了最低注册资本要求、法定缴纳出资期限的限制，对股东出资责任的认定产生了巨大影响，众多学者注意到了“迷雾”中的出资期限给实践带来的巨大挑战，关于未届出资期限的股东能否加速到期的问题产生了大量的研究成果。

关于瑕疵出资股东的责任形态。2013 年《公司法解释（三）》的出台在学界掀起一股研究公司法上补充责任的热潮，但学者多对“补充性”持“默认”的态度，鲜少见到

[1] 参见黄忠顺：“论执行当事人变更与追加的理论基础”，《北京科技大学学报（社会科学版）》，2013 年 4 月，第 99—103,108 页。参见李浩主编：《强制执行法》，厦门：厦门大学出版社，2004 年版，第 1 页。

中国知网 https://www.cnki.net

对“补充责任”的合理性、合法性的论证，也鲜有学者关注到《公司法解释（三）》与《公司法》对于瑕疵出资责任形态的矛盾立场。

关于执行当事人变更、追加制度。首先，对于其理论基础，学界基本形成共识，认为是执行力主观范围扩张导致，但也有学者持否定看法，认为执行力主观范围扩张只能对部分执行变更、追加之事由进行解释。其次，2016 年《变更、追加规定》出台后，对于该命题的研究又兴起了一波新的浪潮，最近几年的研究成果总体上看数量较多、观点之间的争议十分明显，且对于传统观点的颠覆较大；但多数学者的论证说服力不足、缺乏系统性，不具有长久的生命力。最后，既有研究成果多从整体的视角来研究执行当事人变更、追加制度，鲜少以某一类或某一个特定的事由为落脚点，具体研究其变更、追加的制度原理。

关于瑕疵出资情形导致的执行追加。目前对股东出资责任的实现方式的研究集中于诉讼领域，例如对公司法上出资责任的诉讼形态的研究，至于通过强制执行方式的实现，也即执行当事人的变更、追加，既有研究成果要么根本未关注到、要么从系统、整体视角探知略涉皮毛，单独探讨者，甚为少见。

（二）论题的理论意义及实践意义

瑕疵出资责任的实体法渊源与程序法渊源均经历了一个不断变迁的过程。从《公司法》到《公司法解释（三）》，责任形态从一般有限责任演变为补充有限责任；从 1998 年的《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》（以下简称《执行规定（试行）》）、2015 年的《<民诉法>解释》，到 2016 年印发的《变更、追加规定》，程序规则从代位执行转变为执行当事人变更、追加，部门立法与司法解释之间的规则转变、司法解释与司法解释之间的规则流变，使得瑕疵出资责任的执行实现障碍重重。

加之资本制度的变迁，为鼓励投资创业，开拓投资资源，推动公司设立与发展，于公司法修订时，多项措施并举：取消了最低注册资本要求、最低首次出资比例要求、缴足出资期限限制，取消了实收资本工商登记、强制验资制度等，进一步降低公司设立门槛、放宽市场准入条件。从长远角度看，资本信用向资产信用的转变有助于倒逼社会信用体系的建设，但也给司法实践带来了诸多现实问题。执行程序需要实现的目标是迅速

中国知网 https://www.cnki.net

实现债权，在社会信用体系尚未建立健全的背景下，为了最大限度的保护公司债权人的利益，兑现胜诉方的合法权益，执行程序需要的是加大制裁和打击抗拒、逃避执行的力度，资本制度的变革使得债权人通过执行追加获得瑕疵出资债务的清偿更加困难。因此，有必要对上述法律及司法解释进行梳理，并在此基础上探究其理论基础。

另一方面，《变更、追加规定》在具体规则设定上仍存在漏洞，加剧了瑕疵出资情形下执行追加制度的适用困难，因而有必要对其程序规则提出完善方案，以期制度能够更好地运行。

（三）论题的研究方法及创新

本文采用的代表性研究方法包括：第一，实体法学与诉讼法学相结合的方法。瑕疵出资股东的执行追加这一命题，以股东出资责任的责任形态、实体规范及程序规则为基础，命题之展开必然于实体法与程序法“上下求索”。第二，法解释学的方法。综合运用文义解释方法、目的解释方法、体系解释方法等多种法律解释方法，解读民事实体法与程序法对瑕疵出资股东责任的系列规定，后续之论述建立在对于法律条文隐含的立场及其构建的制度的正确解读之上。

本文的创新之处在于：第一，选题新颖，探究瑕疵出资这一特定情形下的执行追加，着眼于特殊性。第二，观点新颖，对于瑕疵出资股东对外所生之责任的责任形态，回归公司法的一般有限责任的基本立场。

中国知网 https://www.cnki.net

一、瑕疵出资股东执行追加制度的演变历程

瑕疵出资，在学界存在“广义说”与“狭义说”之分。持“广义说”之观点者，认为瑕疵出资包含虚假出资行为与抽逃出资行为，虚假出资进一步可分为完全未出资、未足额出资以及未适当出资；持“狭义说”观点者则认为瑕疵出资专指在公司设立阶段，有限责任公司设立时的股东或者股份有限公司的发起人股东，存在未出资、未完全出资或者出资不适当等情形，不包含抽逃出资行为。[2]

笔者拟采“广义说”之观点，理由如下：第一，虽狭义的瑕疵出资与抽逃出资分别产生于公司设立阶段与运营阶段，在具体表现上存在一定差异，但与本论题相关的是二者责任形态的问题，公司法及司法解释对于狭义的瑕疵出资行为与抽逃出资行为的责任形态之规定趋于一致；第二，执行当事人追加的程序规则认可的出资责任人包括狭义的瑕疵出资责任人、抽逃出资责任人以及转让瑕疵股权的责任人三类，其中第三类转让瑕疵股权行为实际上是变相的狭义瑕疵出资行为，实质上仍为狭义的瑕疵出资责任。换言之，执行追加程序规范一并认可了狭义的瑕疵出资行为与抽逃出资行为，并且规定了相同的具体程序规则，从执行追加程序上看，二者并无区别讨论之必要。

瑕疵出资股东执行追加制度，作为实体法与程序法交叉领域的命题，受实体法与程序法的双重规范：实体法规范赋予权利、课以责任，执行法规范设定实现权利、落实责任的具体规则。具言之，公司法及其司法解释明确瑕疵出资行为的责任形态，公司资本制度又影响了瑕疵出资行为的认定标准，追加执行当事人的相关程序规范为瑕疵出资责任的具体落实提供明确的程序指南。

（一）从间接概括到直接具体：执行程序规则的演变

1.间接性概括提出：1998 年《执行规定（试行）》

当享有金钱给付请求权的债权人获得对债务人的胜诉判决后，发现债务人难以履行清偿责任，但享有对第三人的到期债权，此时，债权人既可依据《合同法》第 73 条之

[2] 参见刘俊海：《公司法学》，北京：北京大学出版社，2008 年版，第 102～103 页。

中国知网 https://www.cnki.net

规定，对该第三人提起代位权诉讼，也可径直于原执行程序中启动对债务人的到期债权的强制执行，略去诉讼程序，直接获得清偿。

对债务人到期债权的执行，在我国语境下，也被称为代位执行，指的是债务人对第三人享有到期债权，但该第三人怠于履行债务，导致债务人难以清偿执行名义确定的债务，适时法院可根据当事人的申请，对负担到期债务的第三人强制执行。[3]代位执行萌芽于1992年《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》（以下简称《意见》），其中第300条初步确立了代位执行；规则形成于1998年《执行规定（试行）》，其中第七章“被执行人到期债权的执行”较为详尽的设定了代位执行的程序细则，至此，制度才真正具备了可行性。

股东基于其瑕疵出资行为，对公司承担补足出资债务，又公司对外部债权人负担需为清偿之到期债务，故于公司与债权人间的执行案件中，针对瑕疵出资股东之执行，实为对债务人到期债权之执行，也就是代位执行。根据《执行规定（试行）》的指引，公司对瑕疵出资股东享有的补足出资债权属于执行债务人对第三人的到期债权，应纳入到执行标的的范畴，如能经法定程序认定为到期债权，在执行程序中就可直接对其强制执行。

但是，《执行规定（试行）》又于第九部分“被执行主体的变更和追加”第80条中规定了出资不实、抽逃出资的开办单位可以被追加为被执行人，这一规定就使得瑕疵出资股东出资债务的执行规则变得捉摸不定了。

《执行规定（试行）》第九部分认可的可追加执行的事由包括：作为债务人的私营独资企业难以清偿时，追加执行其业主；合伙组织无力履行时，追加执行其合伙人；无法人资格的分支机构无力履行时，追加设立该分支机构的企业法人等。实际上，本部分规定的执行追加情形，均为欠缺完整法人资格的执行债务人难以清偿时，追加真正的责任人为被执行人。鉴于此，从司法解释的条文部署上可推知，执行追加制度设计之初意在穿透无独立法人人格的主体，落实对真正责任人的强制执行。

《执行规则（试行）》第80条规定显然应从此种意蕴来进行解释。回到第80条，该条文的制定出台具有特殊的历史背景，2005年法人人格否认制度才最终入公司法，在此之前，公司股东绞尽脑汁运用各种计谋，滥用公司法人资格、违法侵占和转移公司财

[3] 参见吴英姿：“代位执行之我见”，《南京大学法律评论》，1998年秋季号，第157—164页。

中国知网 https://www.cnki.net

产、悬空债权、欺诈坑害债权人的情形比比皆是，但是法官面对这些无赖股东，却一筹莫展、无计可施。[4]为解决上述难题，司法解释机关开始在多个领域进行改革试点，1994年最高法在《关于企业开办的其他企业被撤销或者歇业后民事责任承担问题的批复》（以下简称《批复》）中规定，开办单位对其开办的企业法人投入资金未达到最低注册资本要求的，认定为不具备法人资格，由开办单位承担相应责任，随着该《批复》在审判与执行实践中的广泛运用，实缴资本是否达到最低注册资本实际上成为了是否构成法人人格否认的判断标准。《执行规定（试行）》第80条在规则制定的逻辑上与《批复》一脉相承：对于控制股东虚假出资或抽逃出资，只有在导致公司资产显著不足、构成法人人格否认情形下，才对出资瑕疵的控制股东课以更为严苛的责任，在执行中直接将其追加为被执行人，对其进行强制执行。[5]

但是，第80条具体内容的概括性、模糊性，造成了司法实践部门广泛存在对此条文的误解。首先，条文内容极具概括性，第80条确认了“开办时投入的注册资金不实”和“抽逃注册资金”这两种特定瑕疵出资情形下可以进行执行当事人的追加，但缺乏对“注册资金不实”、“抽逃注册资金”进一步的解释，导致了实践中对本条的误用，必须澄清的是，对于出资上存在瑕疵，但不足以否认法人人格的股东，不应对其追加执行。其次，条文规定极具模糊性，规定可被变更、追加的主体为“开办单位”，“开办单位”这一表述行政色彩十分浓郁，且其内涵外延均尚无定论，导致了实践部门对该条文的扩张适用，将“开办单位”扩大解释为“投资人”，认为其外延大致与“股东”相等同，并将该条文作为对瑕疵出资股东进行执行追加的法律依据。但只需对“开办单位”稍作检索，即能发现此种扩张适用并未得到解释机关的认可：2017年人力资源社会保障部发布的《<劳动人事争议仲裁办案规则（修订草案）>（征求意见稿）》，于第7条作如下表述“将其出资人、开办单位或主管部门作为共同当事人”[6]，也就是将“开办单位”和“投资人”理解为并列关系的两方主体；2009年刊登于《人民司法（应用）》的司法解释性文件《<关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要>的理解和适用》中也

[4] 参见刘俊海：《现代公司法（第三版）上册》，北京：法律出版社，2015年版，第662页。

[5] 参见黄金龙：《<关于人民法院执行工作若干问题的规定>实用解析》，北京：中国法制出版社，2000年版，第250页。

[6] 《<劳动人事争议仲裁办案规则（修订草案）>（征求意见稿）》第7条规定：发生争议的用人单位未领取营业执照、被吊销营业执照、营 业执照到期继续经营、被责令关闭、撤销以及用人单位解散、歇业，不能承担相关责任的，依法将其出资人、开办单位或主管部门作为共同当事人。

中国知网 https://www.cnki.net

有类似表述。[7]换言之，“开办单位”与“投资人”并非同一主体，更类似于公司法中法人股东或单位投资人所指称主体，不能包含自然人股东。实际上，对“开办单位”的理解应该结合条文制定背景来考虑，法人人格否认制度着力点在于增强对于控制股东滥用权力的防范与惩治，《执行规定（试行）》制定出台之际，掌握公司控制权的大股东绝大多数为法人或单位主体，因而第 80 条所规定之执行追加对象应限于掌握控制权的“开办单位”，实践中部分法院将自然人股东囊括在内予以追加，实际上是对该条文的扩大解释，甚至存在类推适用之嫌。

环观《执行规定（试行）》之规定，实际上是根据瑕疵出资行为所产生的后果不同而进行了差异化规制：对于一般性的出资上的瑕疵，解释机关视其为“债务人的到期债权”，交由代位执行来予以强制执行，对于以“开办单位”为代表的控制股东的出资瑕疵，因其极易造成公司资本弱化，从而引发对公司法人人格的否认，应交由第 80 条规定的执行当事人变更、追加来调整。换言之，《执行规定（试行）》规范之内容，于本论题所讨论之瑕疵出资而言，仍属于一种间接的、概括的法律规制。

2.直接性具体规定：2016 年《变更、追加规定》

时移世易则法变。随着经济体制改革的不断深化以及《公司法》的数次修订、四部公司法解释的出台，1998 年《执行规定（试行）》的规定在执行瑕疵出资股东的补足出资债务时常常左支右绌。《执行规定（试行）》规定的代位执行与执行追加并行的模式使得司法解释机关的意旨扑朔迷离，尤其是第 80 条之规定直接涉及“出资不实”、“抽逃出资”的字样，致使代位执行在解决瑕疵出资股东与债权人间的法律关系时，大有被“喧宾夺主”之态势，在实践中，第 80 条渐渐偏离了解释机关的初衷，实践部门对其扩大解释、类推适用的现象屡见不鲜，例如部分法院为最大化、最高效化实现实体权益、保障债权人合法权益、惩处规避执行行为，对第 80 条进行扩张解释，将“开办单位”的外延与“股东”相等同，基于该条文，对瑕疵出资的自然人股东进行执行追加。[8]必须承认的是，基于该条文追加执行瑕疵出资股东，存在类推适用法律渊源之嫌疑。[9]另有部

[7] 参见高尚民：“《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》的理解和适用”，《人民司法（应用）》，2009 年第 9 期，第 29—42 页。。

[8] 例如上海市高级人民法院 2015 年印发的《2005 年上海法院民商事审判问答（之五）》（沪高法民二[2005]12 号）中提及：“法院以公司股东出资不实为由追加其为被执行人”，实际上印证了司法实践中对《执行规定（试行）》第 80 条扩张适用的存在。

[9] 参见张欢、洪宁：“公司资本制度改革后股东追加执行的困境与突破”，《上海政法学院学报（法治论丛）》，

中国知网 https://www.cnki.net

分法院认为强制执行中应遵循“执行力主观范围扩张法定原则”，在执行过程中，变更、追加执行主体应严格遵照执行相关法律、司法解释的规定进行，法无明文规定即为禁止。[10]但在执行程序中，到底应当如何处理债权人与瑕疵出资股东之间的债权债务关系，法院也多建议债权人另行提起诉讼，获得胜诉判决后再申请强制执行，司法解释赋予的代位执行的执行方式在瑕疵出资责任的追究上，并没有得到实践部门的充分认可。因此，对瑕疵出资股东补足出资债务的执行，需要更加明确具体的法律规范，以提供更加清晰直接、更具可操作性的法律指引。

为消除执行中混乱无序的状态，迅速解决执行难基本问题，2016 年最高人民法院印发了《变更、追加规定》，将对承担出资责任的股东的强制执行统一交由执行当事人的变更、追加来实现：在规定第 17～19 条，采用列举式的立法方式，在《执行规定（试行）》的基础上，对瑕疵出资股东的执行追加作出了更加明确、具体的规定。具言之，在公司无力清偿债务时，第 17 条规定可追加执行瑕疵出资的股东、出资人或依法承担连带责任的发起人，请求其在尚未缴纳出资范围内承担清偿责任；[11]第 18 条规定可追加执行抽逃出资的股东、出资人，请求其以抽逃出资范围为限承担清偿责任；[12]第 19 条规定可追加执行未完全履行出资义务即转让股权的股东或依法应承担连带责任的发起人，请求其在未依法出资的范围内承担清偿责任。[13]

较之《执行规定（试行）》，首先，《变更、追加规定》出台之际，公司法改革后已经废除了最低注册资本要求，这意味着 1994 年《批复》创设的根据最低注册资本来判断公司资本是否显著不足的标准已全线失灵，瑕疵出资行为滤去了法人人格否认的色彩，其性质在于违反股东的出资承诺，构成对其他信守承诺如约出资股东的违约，间接

2015 年第 6 期，第 116—122 页。

[10] 北京市高级人民法院 2010 年 7 月印发的《北京市法院执行工作规范》第 511 条规定：在执行过程中，变更或追加执行当事人的，应当严格按照执行方面法律、司法解释的规定进行；没有明确规定可以变更或追加执行当事人的，不得变更或追加。

[11] 《变更、追加规定》第 17 条规定：作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。

[12] 《变更、追加规定》第 18 条规定：作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人在，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。

[13] 《变更、追加规定》第 19 条规定：作为被执行人的公司，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，其股东未依法履行出资义务即转让债权，申请执行人申请变更、追加该原股东或依公司法对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在未依法出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。

中国知网 https://www.cnki.net

侵害了公司债权人对公司信用的可预期性，损害了债权层面的交易安全。[14]但股东出资不诚信导致公司资本弱化、欠缺偿债能力的问题在实践中仍然十分严峻，基于尊重多年来的习惯做法、维持司法现状和着眼该种关系的特殊性、解决实践中的乱象，《变更、追加规定》认可了对瑕疵出资股东的追加执行；其次，在被追加主体上真正与实体法的规定相一致，直接点明到“股东”、“发起人”等具体责任主体，而不再如隔窗纱，似是而非；再次，关于瑕疵出资情形之规定更加丰富、具体，增加了转让瑕疵股权情形下的执行追加的规定，进一步解释了“出资不实”所指称情形，明确了具体的瑕疵出资情形下执行当事人变更、追加制度的适用，助推实体权利的实现，保障债权人的合法权益；最后，对瑕疵出资股东的执行追加程序和救济程序作出了具体而详细的规定。

《变更、追加规定》将出资责任的执行实现与实体法的规定基本衔接起来，为债权人实现债权提供了直接具体的“操作指南”以及体系相对完整、制度相对完善的法律指引，遗憾地是，执行程序规则的流变，欠缺对其合理性、合法性的论证，尤其是关于代位执行的性质目前争议广泛，这也为制度落到实处留下了隐患。

综上所述，从 1998 年《执行规定（试行）》到 2016 年《变更、追加规定》，瑕疵出资股东对公司债权人的补足出资的债务的执行程序规则经历了一个由间接规范到直接调整、概括规则到具体确定的变迁。

（二）从一般有限到补充有限：瑕疵出资责任的演变

本来公司债权人的保护属于合同法与担保法的重大责任，公司法本不必涉足债权人保护之事。但念及公司作为债务人时，公司面纱背后的股东有可能滥用公司制度逃避债务，公司法不得不从自己的独特视角呵护公司债权人。

诚如斯言：“粗放型公司制度的现代化不仅要求立法者在股东投资方面融入主流公司制度文明，且要求立法者在维护交易安全方面也要见贤思齐，有所作为。”[15]较之股东，债权人作为“外人”无权参与公司的内部治理，进而其想要获知公司真实的资产信息、经营信息也阻碍重重，往往需付出高昂的成本，如不对公司股东的出资行为加以规制，无疑将给公司债权人带来灾难，并最终动摇公司制度存在的根基。另一方面，为缓

[14] 参见刘俊海：《现代公司法（第三版）上册》，北京：法律出版社，2015 年版，第 208 页。
[15] 参见刘俊海：《现代公司法（第三版）上册》，北京：法律出版社，2015 年，第 663 页。

中国知网 https://www.cnki.net

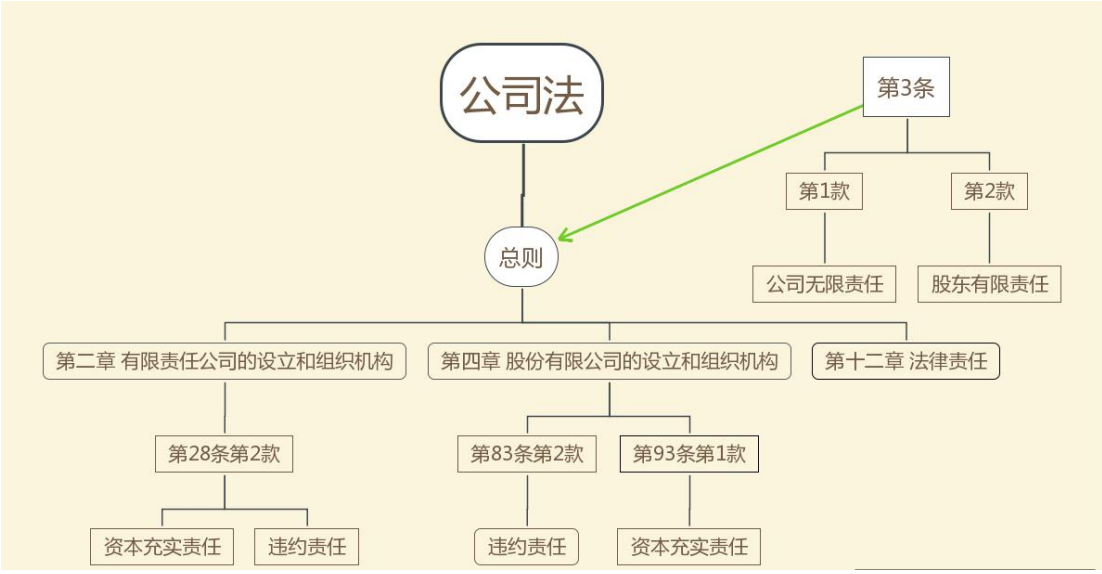
解股东有限责任对交易安全的冲击，保护善意的外部债权人，公司法也需要妥当配置内部主体与外部主体间的权利与义务、责任与风险，通过良性的顶层设计化解利益冲突、实现股东与债权人的利益均衡、多赢共享，而规范股东出资即是保障公平均衡的第一道防线。[16]

1.一般性有限责任：《公司法》的原则性基本立场

如前所述，规范股东出资在保证公司资本充实、维持公司良性运营、保障外部债权人的利益上卓有成效，域外国家或地区立法先后都对股东课以严格的出资责任，我国公司法自然也要有所作为：在公司资本三原则的基础上，明确规定了瑕疵出资股东应承担出资违约责任及差额填补责任。

《公司法》对瑕疵出资股东的法律责任规定如下（见图 1）：

（图 1：《公司法》规定的出资责任示意图）



具言之，其一，第 3 条第 1 款规定公司以其全部财产对外承担无限责任，第 2 款规定股东以其出资为限，对外承担有限责任，责任范围根据公司性质不同而有差异，分别为认缴的出资额及认购的股份。

其二，在《公司法》第二章“有限责任公司的设立和组织机构”部分中，第 28 条第 2 款规定了股东基于瑕疵出资负担的双重责任：向公司足额缴纳出资、向已适当履行

[16] 参见潘勇锋：“论瑕疵出资人责任范围——以对公司债权人承担的责任为限”，《北京仲裁》，2013 年第 86 辑，第 70—84 页。

中国知网 https://www.cnki.net

出资的股东承担违约责任，但是并未谈及上述股东因瑕疵出资对公司债权人所生之债；于第四章“股份有限公司的设立和组织机构”部分，第 83 条第 2 款规定未按公司章程规定适当履行出资义务的股份有限公司发起人，应根据发起人协议承担违约责任，第 93 条第 1 款规定未如公司章程规定缴足出资的发起人，应对公司承担补缴出资的义务，同样立法者也未于股份有限公司的特别规定中提及瑕疵出资的发起人对公司债权人所生之外部责任。

其三，《公司法》第十二章“法律责任”部分规定了“虚假出资”、“抽逃出资”等情形下的股东或发起人的法律责任，但责任性质属于行政责任，与本论题所探讨之民事责任相去甚远，不作赘述。

根据上述分析，瑕疵出资责任主体对外部债权人负担的责任的具体形态，《公司法》语焉不详，具体规定付之阙如，依照成文法解释的基本法理，必须依据条文“编章节条款项目”之前后关联位置、或相关法条之法意来阐明规范之意旨，唯如此方能维护制度体系之一贯、概念用语之一致。[17]对于条文中具体章节未作特殊规定的，应参照总则的一般性规定，准予此论，瑕疵出资股东对于公司债权人所负担之责任，应持一般有限责任的基本立场，也就是具体规则缺位时，受总则约束，由总则调整。

除《公司法》外，瑕疵出资股东对债权人承担清偿责任，亦源于《合同法》第 73 条关于债权人代位权的规定，这一点与《执行规定（试行）》保持了逻辑上的统一，在债权人面前，公司为债务人，瑕疵出资股东为次债务人，当公司怠于行使其到期债权，且可能损害债权人的债权时，债权人可突破债的相对性原则，直接向次债务人主张权利。《合同法》未对公司债权人行使代位权设定清偿不能的条件，瑕疵出资股东向公司债权人所履行之责任仍为一般有限责任。

综上，《公司法》对于股东和公司债权人之间的关系调整，重点在于确认有限责任制度，核心是在公司与股东之间划下一条明显的界限，至于瑕疵出资股东所承担之责任的规范上，仍持原则上为一般有限责任的基本立场。

2.补充性有限责任：《公司法解释（三）》的变通

在《公司法》所确认的有限责任框架下，股东只是单纯的投资者，无须对公司的债

[17] 参见杨仁寿：《法学方法论》，北京：中国政法大学出版社，1999 年版，第 107 页。

中国知网 https://www.cnki.net

务承担除投资之外的其他外部责任。2014 年《公司法解释（三）》在《公司法》规定的基础上，对瑕疵出资股东对债权人所负担之补足出资责任的形态作出了调整，对《公司法》所持之一般有限责任形态的原则性立场作出变通：将间接的债权债务关系法定化，并赋予其补充性，使其成为补充有限责任，也就是学界常说的“公司法上的补充责任”。

《公司法解释（三）》第 13 条第 2 款规定瑕疵出资股东对债权人负担补充赔偿责任[18]、第 14 条第 2 款对于抽逃出资股东的责任作出类似规定[19]。根据上述规定，瑕疵出资股东对债权人承担补充赔偿责任，该责任在性质上属补充责任，其表现形态具有特殊性。

具体而言，《公司法解释（三）》关于股东因瑕疵出资而生的外部责任的规定，对《公司法》立场的变通主要表现在责任的法定性和责任的补充性上。其一，责任的法定性。指的是股东与公司外部债权人之间通常不存在直接的债权债务关系，本应由债的代位制度将二者间接关联起来，《公司法解释（三）》通过条文的明确规定，在债权人与股东之前搭建了一道桥梁，当股东存在瑕疵出资行为，且公司不能清偿债务时，赋予债权人对瑕疵出资股东的直索权，这是因为公司法本身蕴含着浓郁的公法色彩，承担了大量的促进市场公平、防止私法自治失灵的任务，基于债权人相对于股东的弱势地位，均衡保护二者的利益需要对股东课以特别的责任。其二，责任的补充性。从责任的实现方式来看，公司是直接的责任主体，应首先以其财产对债权人承担责任；瑕疵出资股东属间接的责任主体，在责任的承担上具有顺位利益，处于补充地位。换言之，只有当公司无力清偿时，债权人才能就其不能清偿部分请求瑕疵出资的股东履行义务。随补充性应运而生的是先诉抗辩权的问题，基于补充性质的要求，补充责任在效力上应以先诉抗辩为原则，以此强调是对债务人清偿不能的补充，而非债务人拒绝偿债的补充。[20]

综上所述，瑕疵出资股东的执行追加制度，在执行规则上，经历了从代位执行到执行追加的规则流变；在责任形态上，经历了从一般有限到补充有限的实体法渊源变迁。

---

[18] 《公司法解释（三）》第 13 条第 2 款规定：公司债权人请求未履行或者未完全履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，人民法院应予支持。

[19] 《公司法解释（三）》第 14 条第 2 款规定：公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，人民法院应予支持。

[20] 参见李中原：“论民法上的补充债务”，《法学》，2010 年第 3 期，第 78—91 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）从资本实缴到资本认缴：资本缴纳制度的演变

资本制度是公司制度的核心，其与法人人格否认制度一张一合，共同构成现代公司制度保护债权人、维护交易安全的两道基本防线。最近一次公司法修订兴利除弊，积极稳妥的推进资本制度变革，以其为时间节点，此前为注册资本实缴登记制，其后彻底转变注册资本认缴制，为宽进严管的公司监管制度变革扫清障碍。从实缴制到认缴制的扭转，核心在于：一是充分尊重股东的意思自治，将股东出资的金额和期限授权公司自治；二是充分保障股东认缴及实缴出资信息的真实性、准确性，使得对瑕疵出资治理的锋线向后推移，瑕疵出资的认定及追责由事前转向事后。[21]

1. 资本信用理念下的实缴制：2013 年修正前的《公司法》

公司资本在公司存续与运营的过程中扮演着极其重要的角色，为公司稳定发展提供了物质基础；对债权人而言，公司资本展现了公司的信用能力，是其作出商业判断的重要决策依据。在注册资本实缴制下，注册资本是公司资产最原始、最直接的来源，公司注册资本直接展示了公司信用能力，成为债权人判断交易对象是否值得信赖，交易是否安全的主要依据。鉴于此，资本实缴制意图通过强制性规定、“铁腕规则”设置严格的准入条件，确保公司资本的充实和稳定，夯实公司生存与腾飞的基础，巩固交易的安全，保障债权人的合法权益。

资本实缴制的核心在于最低注册资本制度，该制度要求股东在公司设立之初即缴纳充足的资本，确保公司在诞生之初就拥有足够保护债权人及其他利益相关主体的物质基础，最低注册资本制度是强化前端控制的典型。

在最低注册资本要求、法定出资期限、最低缴纳比例等刚性的、强制性的法律规定制约下，实缴制下瑕疵出资的认定标准十分明确，加之强制验资的要求、实收资本强制进行工商登记，股东出资是否存在瑕疵一目了然，实践中瑕疵出资纠纷往往沦为证据收集、数据解读等技术层面的问题。

[21] 参见刘俊海：《现代公司法（第三版）上册》，北京：法律出版社，2015 年版，第 194 页。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 资产信用理念下的认缴制：2013 年修正后的《公司法》

与此前通过设置高门槛、严格监管注册资本来维持公司的良性运营及均衡保障各方利益的相区别，此次《公司法》修订处于优化营商环境改革的浪潮中，激发市场活力、释放改革红利等目标的实现对公司法提出了更高的要求，敦促公司法必须在尊重和捍卫私法自治、预防和矫正市场失灵上更有建树，因此公司法修订需要破除高门槛，重新释放被抑制的投资活力和市场活力，在尊重公司自主运营及保障债权人利益之间找到新的制度平衡。

良好的公司资本制度应该在均衡股东及债权人利益的基础上，利于公司经营，既不闲置资本，也不至于“无米下锅”。[22]实缴制下，资本制度侧重于债权人的保护，通过强制性地设定资本最低限额，为债权预留最低限度的公司资产，以缓解有限责任对交易信心的冲击，同时资本数额的限制也在一定程度上保障了公司的正常运营。但是刚性的最低注册资本制度在保护债权人上功能十分有限，反而极大地抑制了市场活力，在实践中成效不彰，域外最低注册资本制度日渐式微即是一个有力的注脚。

随着最低注册资本神话的破灭、经济形势的转变，此次修订《公司法》主要针对公司资本形成阶段的资本制度进行了改革，遵循“简政放权”原则，滤去了过去公司设立中对于“小资本”的歧视，矫正了制度的异化，将传统的“资本法定”改为“资本章定”，软化资本维持原则，在对公司债权人的保护上采后端控制策略，释放投资者投资兴业的积极性与创造性，为投资者“白手起家”疏通了制度障碍。但是随着前端管控的弱化，因出资问题而产生纠纷的隐患显著增强，加之废除了货币出资的“天花板规则”、在出资期限上给予股东更大的自由，必然导致公司资产结构更加复杂，公司资产“注水”、虚报市值的情况愈加严重，对市场主体的活力激发、营商环境的优化造成严重的损伤，因此，在认缴制下，依然要出重拳遏制瑕疵出资行为。[23]

于本论题而言，较之实缴制，资本认缴制下产生了以下变化：

其一，瑕疵出资的争端重心后移，如前所述，资本认缴制改革后，缓和了一系列的前端控制机制，例如改革工商登记、变革实收资本必要记载事项的地位，取消强制验资、修改年检制度为年报制度等，外部标识的弱化使得股东瑕疵出资的问题更加隐蔽，收集

[22] 参见富饶：“公司资本诉讼研究”，吉林大学博士学位论文，2017 年，第 31 页。
[23] 参见刘俊海：《现代公司法（第三版）上册》，北京：法律出版社，2015 年版，第 164—197 页。

中国知网 https://www.cnki.net

真实信息的高昂成本使得债权人对瑕疵出资股东的清偿请求在执行阶段集中爆发出来。

其二，将实缴注册资本的金额及期限由法定改为授权公司章定、股东自行承诺，使得瑕疵出资与法人人格否认正式“脱钩”。如前所述，资本认缴制改革废除了最低注册资本要求，1994 年《批复》创设的根据最低注册资本来判断公司资本是否显著不足的标准难以为继，对于公司资本是否充足只能依赖于股权资本与债权资本的比例来进行评价，且需综合行业性质、经营规模、雇工规模等其他因素来衡量，这意味着出资是否存在瑕疵不再影响是否“揭开法人面纱”的司法评价，出资责任应定位于违背股东自己作出的出资承诺，构成对其他信守承诺如约出资股东的违约，并间接侵害了公司债权人对公司信用的可预期性，损害了债权层面的交易安全，而法人人格否认则在于要求股东量力而为，不随意“以小博大”，适度投机。

其三，认缴制改革同时废除了法定出资期限的规定，这一举措给瑕疵出资的认定产生了极大的现实困境。将出资期限完全交由股东自治，恰好给股东提供了“空手套白狼”的机会，实践中约定十年、二十年甚至更长缴纳期限的公司屡见不鲜就是一个有力的注脚，当公司无力清偿时，该章定期限效力几何，能否对尚未届出资期限的股东适用加速到期制度，成为当前实践中瑕疵出资争议中最棘手的问题。

二、瑕疵出资股东执行追加程序的现实困境

诚如斯言，在当前状况下，立法决策结果的产生有赖于：其一，问题被视为亟待解决且可被解决；其二，问题已有合适的解决方案；其三，权力平衡有利于该种解决方案的选择；其四，有选择该方案的机会。[24]瑕疵出资责任的执行追加实现方式被司法解释正式确认下来，其相对于诉讼路径的巨大效率优势自不待言，还得益于其在实践部门被广泛认可、在消化积压的执行案件上成效显著。

但是，由于实践难题亟待解决、实践部门对于解释出台的呼声高涨，《变更、追加规定》匆匆出台，欠缺充分的论证，导致其法理基础到底为何争议重重、规则到底如何适用矛盾重重、程序到底如何操作问题重重，制度实效到底如何发挥困境重重。

[24] 参见刘安：《中国公司法律制度——政治经济学维度的解释》，北京：北京大学出版社，2017 年版，第 94 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（一）法理基础争议重重

1.程序法理上的争议

程序法理上的争议主要表现在以下三个方面：

（1）另诉审判救济与执行追加救济之争

该争议焦点在于能否不经审判程序确认债权人对瑕疵出资股东享有的债权，就直接在对公司的执行中追加股东为被执行人，执行该股东的财产。

支持另诉审判救济者认为追加执行瑕疵出资股东背离了传统诉讼原理，不具正当性，认为债权人应当首先通过审判确认权利，获得新的执行名义，再针对该执行名义提起强制执行。因为审判程序与执行程序二者功能定位不同、活动原则不一，审判程序旨在确证权利、裁决争端、作出实体性判断，而执行程序旨在快速实现权利，一般应遵照形式主义原则，也就是不应涉及任何实体问题。但是处理债权人与瑕疵出资股东之间的关系，必然涉及对被执行人对第三人有无债权存在、债权数额范围如何等实体问题的判断，如未经审判程序加以判断，即依执行机关的命令或裁决而成为确定的权利状态，在学理上难于想象。[25]

2016 年《变更、追加规定》出台后，执行追加救济的呼声高涨，一方面得益于司法解释的出台，统一了执行追加的主体与实体法规定的瑕疵出资责任主体，卸下了《执行规定（试行）》课以执行追加的防范、制约人格否认的负担，明确了具体程序规则，扫清了执行追加在实践中适用的部分障碍。

但更为本质的，是随着判决既判力、执行力理论研究的深入，尤其是对于判决效力相对性原则的认识的发展，学界对于执行当事人变更、追加制度有了更加系统深入、科学合理的认知。支持对瑕疵出资股东追加执行的学者，多认可债权人获得的确认其对公司享有债权的胜诉判决的执行力可以突破相对性原则，向出资有瑕疵的股东扩张，即执行名义的执行力扩张及于瑕疵出资股东，既然为执行名义的执行力所及，那么自然不必经过审判程序获得新的执行名义，即可在执行程序中直接对其追加执行。

[25] 参见陈荣宗：《强制执行法》，台湾三民书局，2000 年版，第 568～569 页。转引自常廷彬：《民事判决既判力主观范围研究》，北京：中国人民公安大学出版社，2010 年版，113 页。

中国知网 https://www.cnki.net

综合上述分析，另诉审判救济与执行追加救济的争论，实质上是对执行名义的执行力能否突破相对性原则、执行名义能否扩张及于瑕疵出资股东问题的争论。

（2）针对到期债权的代位执行与基于瑕疵出资责任的执行追加之争

该争议为瑕疵出资股东对债权人承担的出资责任在执行程序中应如何实现的问题，具言之，瑕疵出资股东对公司债权人承担的补足出资债务在执行程序中的实现方式，是通过将其认定为债务人的到期债权、经由代位执行来予以强制执行，还是直接将瑕疵出资股东追加为被执行人、对其强制执行。

如前所述，《执行规定（试行）》的条文拟定为此处的争议埋下了伏笔。1998 年《执行规定（试行）》将“被执行人到期债权的执行”与“被执行主体的变更与追加”分别规定于解释第七部分和第九部分，并在第九部分第 80 条执行追加中特别确认了追加瑕疵出资“开办单位”为被执行人的情形，根据条文拟定之逻辑，代位执行与执行当事人变更、追加之间具有相互并列的紧张关系，二者应不具有相互包含或者重合之内容，根据第 80 条规定之内容，追加瑕疵出资的股东向债权人清偿出资，存在扩大解释、类推解释的嫌疑，能否适用尚值得商榷，但是第七部分代位执行规定之内容，于出资责任而言，又过于笼统概括，难以提供具体直接的指引，这直接导致了争论的形成。

争议实质上是对“债务人到期债权”基本原理的认知差异所致，进而对代位执行的执行依据也存在不同看法。

持前一观点者，一般把代位执行的性质界定为一种债权保全的手段，认为代位执行实际上是债权保全职能在执行中的体现。[26]换言之，代位执行的关键在于代位权诉讼或者其他权益判断程序确证了债权人能否请求法院执行次债务人的财产。[27]据该观点，瑕疵出资股东对公司负担的补足出资债务如能经法定程序认定，构成债务人的到期债权，该法定程序所形成的“履行通知”或“执行裁定”就成为新的执行名义，债权人通过代位执行实现对新的执行名义的强制执行。

持后一观点者则倾向于认为代位执行是一种执行措施、执行方法，与抵押、扣押相似，代位执行是针对债务人到期债权这一执行标的的执行措施，针对次债务人的代位执

[26] 参见刘文勇：“再探代位执行程序的理论基础——从代位执行的执行依据及其正当性展开”，《民事程序法研究》，第十八辑，第 95—108 页。

[27] 参见庄加园：“初探债权执行程序的理论基础——执行名义欠缺的质疑与收取诉讼的构造尝试”，《现代法学》，2017 年 5 月，第 132—147 页。

中国知网 https://www.cnki.net

行的执行依据仍为原执行名义，其效力发生了主观范围的扩张而及于次债务人。换言之，针对到期债权的代位执行本质上是执行名义执行力主观范围扩张的情形，对债务人到期债权的执行本应交由执行当事人变更、追加制度来调整，对代位执行的认识则回归到执行措施层面。瑕疵出资股东对债权人负担的清偿责任，可以在执行中予以解决的程序法理在于执行名义的执行力发生了扩张，执行力主观范围及于股东，股东因而成为适格的执行当事人，可以被追加执行，进一步具体如何执行的问题，则应求诸于代位执行措施。

综上，针对到期债权的代位执行与基于瑕疵出资责任的执行追加的争论，实质上是对代位执行性质的看法上的分歧，并进一步导致了对代位执行和执行追加二者关系的认识上的争论。

（3）基于既判力扩张的执行力扩张与超越既判力扩张的执行力扩张之争

在认可瑕疵出资股东执行追加的理论基础在于执行力主观范围扩张的基础上，对于具体隶属于何种执行追加类型又产生了分歧。

持前一观点者认为该扩张情形隶属于基于判决既判力扩张而产生的执行力扩张。持后一观点者则认为，基于既判力扩张的执行力扩张只是执行力扩张的一般样态，除了基于既判力扩张的三类情形产生的执行力扩张的基本样态外，还存在超越既判力扩张的执行力扩张类型，瑕疵出资股东执行追加即属于此类情形。

至于瑕疵出资股东的执行追加到底属于何种类型之执行力扩张，在后一观点内部又产生诸多分歧，主要包括以下几类观点。

其一，基于主体同一性的扩张。所谓主体同一性关系，指的是基于民事主体人格混同、财产混同而产生的执行当事人与第三人之间的同一属性。基于主体同一性的扩张，指的是当事人与第三人因特定的实体法上的关联关系，代替原债务人向债权人履行债务，而产生的执行当事人的变更。[28]该观点认为，股东因出资瑕疵导致公司资本弱化、法人人格不健全，此时瑕疵出资股东与执行名义载明的债务人在主体上具有同一属性，当然为执行力所涵盖。

其二，基于另一实体法律关系的扩张。据此观点，因债权人、公司及瑕疵出资股东之间存在复数的实体法律关系，债权人与公司间的实体法律关系由执行名义确定下来，

[28] 参见魏锋：“执行当事人研究——以执行力主观范围扩张为中心”，中国政法大学博士学位论文，2009 年，第 74 页。

中国知网 https://www.cnki.net

债务人与股东间的法律关系由公司法明确规定，因股东怠于履行或不适当履行出资义务，致使公司难以向债权人履行或完全履行执行名义所确定的债务，鉴于此，执行力有必要向瑕疵出资股东扩张，追加其为执行当事人，要求其直接向债权人履行债务。[29]

其三，基于各种政策目的而确立的政策性扩张。该观点认为将执行名义执行力扩张及于瑕疵出资股东属于政策性扩张，目的在于打击恶意逃债行为，也就是此种扩张仅为解释机关解决“执行难”问题的一种对策。[30]

还有学者认为瑕疵出资股东的执行追加，属执行名义执行力向执行担当主体的扩张。因股东向债权人承担瑕疵出资责任本质上是债权人代位权在公司法上的表达，其基本理论与具体形态均来源于代位权理论，根据我国司法解释之规定，代位权行使要件成立的，次债务人应直接向债权人履行清偿义务，履行完毕后，债权人与债务人、债务人与次债务人之间的债权债务关系即予以消灭，代位权行使的结果归于债权人，准予此论，债权人在执行当中追加次债务人，于执行程序中成立执行担当。[31]

2.实体法理上的争议

实体法理上的争议，源于我国公司法及司法解释之间呈现出“双轨运行”的混乱局面：根据《公司法》的规定，瑕疵出资股东，对内产生到期债权、对外产生一般有限责任，而《公司法解释（三）》对其作出变通，规定瑕疵出资股东对内仍产生到期债权，对外承担补充有限责任。

当前由于学界及实务界对于《公司法解释（三）》第 13 条规定之“补充赔偿责任”持默认的态度，因而实体法上的争议，集中于“补充”的标准上，只有极少学者对于补充责任形态本身提出质疑。[32]

此处所言之“补充”，指的是公司债权人请求瑕疵出资股东承担补充赔偿责任，必须以公司债务“不能清偿”为前提。但是“不能清偿”之认定标准究竟为何尚无定论。学界目前主要有两种观点，第一种观点亦是主流观点，认为“不能清偿”指的是公司债权人就与公司的债务纠纷经过诉讼或者仲裁，并就公司财产依法强制执行后仍然得不到

[29] 参见刘学在、王炳乾：“执行当事人变更、追加的类型化分析”，《政法学刊》，2018 年 4 月，第 86—100 页。

[30] 参见刘书星：“我国执行力扩张制度研究”，《法学杂志》，2015 年第 7 期，第 123—131 页。

[31] 参见马登科：《案外人救济制度研究》，北京：法律出版社，2016 年版，第 198 页。

[32] 关于对补充责任形态的质疑，可参见张其鉴：“论认缴制下股东补充赔偿责任中的‘不能清偿’标准——基于回归公司法立场的分析”，《政治与法律》，2017 年第 3 期，第 142—153 页。

中国知网 https://www.cnki.net

完全清偿，否则瑕疵出资股东享有先诉抗辩权。持此观点者，认为股东享有顺位利益，可行使先诉抗辩权，主要理由如下：第一，先诉抗辩权产生于一般保证领域，瑕疵出资的补充赔偿责任在一定程度上借鉴了一般保证责任的结构，将一般保证人的先诉抗辩权类推适用于瑕疵出资责任中具有合理性；第二，先诉抗辩权是补充性的本质要求，补充性归根结底强调的是在责任承担上的补充，先诉抗辩赋予了当事人在责任承担上的顺位利益，确保了责任补充性的实现。第二种观点认为，债权人应首先请求公司清偿债务，无论公司是否具备偿债能力，只要公司拒绝偿债，债权人就可以请求股东向其履行出资义务。换言之，瑕疵出资股东责任的补充性指的是对拒绝清偿的补充，而非无力清偿的补充。因为股东的补充赔偿责任有别于一般保证责任，本质上是股东履行自己的出资义务，其向债权人的履行可以看做出资责任的变通履行方式；如果瑕疵出资股东享有先诉抗辩权，那么强制执行程序适用于股东出资债务时会出现逻辑悖论。但根据后一观点，既不具备追偿权、又不具有先诉抗辩权，那么该责任是否属于补充责任则值得商榷了。

综上，瑕疵出资股东执行追加的实体法理上的争议主要表现在两方面：瑕疵出资对内产生到期债权、对外产生一般有限责任与补充有限责任之争；在对外生补充有限责任的观点之下，又进一步产生了瑕疵出资责任对外是否享有先诉抗辩之顺位利益的争论。实体法理上的重重争议，使得瑕疵出资股东的执行追加适用更加困难，在实践中陷入混乱。

（二）规则适用矛盾重重

1.实体规则与实体规则间的矛盾

如前所述，《公司法》与《公司法解释（三）》对于瑕疵出资责任的规定呈现“双轨并行”的态势，二者对债权人与瑕疵出资股东之间的债权债务关系的看法差异表现在两点：责任的法定性与补充性上。

其一，责任法定。在《公司法》的立场下，债权人需根据《合同法》，通过代位制度要求瑕疵出资股东向其给付。根据《合同法》之规定，债的代位的构成要件包括：第一，债务人对第三人享有权利；第二，债务人怠于行使其权利；第三，债务已陷于迟延；第四，对债权人造成损害。因此，债权人向股东主张权利，以经过法定程序认定其与公

中国知网 https://www.cnki.net

司之间的债权债务关系为前提，在此基础上股东确实怠于履行出资义务，公司也怠于主张其债权，且使得公司的资产可能难以完全偿债时，债权人的主张才可能得到支持。但《公司法解释（三）》的规定打破了债权人和瑕疵出资股东间的法律屏障，将《公司法》立场下交由债的代位制度调整的法律关系，直接联结起来，债权人在公司无力清偿债务时对瑕疵出资股东享有了直索权。[33]换言之，《公司法解释（三）》赋予了债权人在一个权利确认程序中、一并解决其与公司的债权债务关系和与瑕疵出资股东的债权债务关系的权利。

其二，责任补充。《公司法》并未对瑕疵出资股东对债权人承担的责任作出特别规定，外部责任应一律为一般有限责任，不具有补充性，显然股东也不具有先诉抗辩权。而《公司法解释（三）》则强化了对公司股东的保护，创设了瑕疵出资股东对外承担责任的前提条件：股东对外担责以公司清偿不能为前提，否则可主张先诉抗辩权，实际上赋予了瑕疵出资股东顺位利益。

综上，基于是否为法定责任，以及责任是否具有补充性上的立场不同，公司法部门立法与司法解释在瑕疵出资股东对债权人承担何种责任的问题上作出了相区别的规定，换言之，实体规则与实体规则之间仍存在着相矛盾的内容。

2.程序规则与实体规则间的矛盾

程序法作为权利确认规范和权利实现规范，其设定必须以民事实体法为基准，尤其是强制执行法，在具体制度设计上应与民事实体法相协调，顺应实体法的要求。但是于程序法而言，呼应实体法并不容易，程序规则与实体规则常常处于一种矛盾的状态，如何遵循实体法的精神、衡平股东自治权利与公司债权人利益之间的冲突，是执行实务的重难点。

（1）责任的补充性

《公司法解释（三）》规定瑕疵出资股东对债权人所承担的清偿责任是一种补充责任，在适用上具有补充性。补充性根源于《公司法解释（三）》第 13 条第 2 款“对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任”之规定，但何种情形下构成“公司债务不能

[33] 参见梁上上：“未出资股东对公司债权人的补充赔偿责任”，《中外法学》，2015 年第 3 期，第 649—664 页。

中国知网 https://www.cnki.net

清偿”，现行法没有明确规定，主流观点从先诉抗辩权的角度，认为基于“补充性”的要求，补充责任在效力上应以先诉抗辩为原则，先诉抗辩权又被称为顺序利益抗辩权，属相对性抗辩，指主债务纠纷经审判或者仲裁，并就主债务人的财产依法强制执行仍未获得完全清偿时，方可请求后顺位的责任人承担责任。[34]换言之，补充指的是对债务人清偿不能的补充，而非债务人拒绝偿债的补充，“公司债务不能清偿”应以公司债权人就与公司的债务争议经过诉讼或者仲裁，并就公司财产依法进行强制执行后仍不能得到完全清偿为标准，否则股东享有先诉抗辩权。

然程序法之规定显然未遵循实体法之要求，也难以遵循其要求。2015 年颁布的《<民诉法>解释》直接继承了《执行规定（试行）》中代位执行规则的内核，规定瑕疵出资股东对债权人所承担之补足出资债务的执行，如能通过法定程序认定为“债务人的到期债权”，则应通过代位执行来对其进行强制执行，而代位执行强调是债务超出资产或信用能力、可能导致清偿无力的状态，而不必以债务人现实的清偿失败为前提。

2016 年出台的《变更、追加规定》第 17～19 条中，虽有“财产不足以清偿生效法律文书确定的债务”的表述，但此处“不能清偿”与《公司法解释（三）》第 13 条第 2 款所言“公司债务不能清偿”，不应具备相同的含义，否则将导致逻辑上的悖论：如果《变更、追加规定》承认瑕疵出资股东对公司债权人所承担之责任具有补充性，享有顺位利益，将导致瑕疵出资情形下，变更、追加执行当事人制度完全没有适用空间，也就是说，如果瑕疵出资股东享有顺位利益，可主张先诉抗辩，则将其追加为被执行人必须以对公司强制执行完毕仍未获得完全清偿为前提，但是执行当事人的变更、追加应发生于执行程序进行中，也就是既要等到案件的执行完毕，又要发生于执行程序当中。换言之，执行追加制度与补充责任、顺位利益的保护存在不可调和的矛盾。

综上，在责任形态的补充性上，程序法规则虽表述不一致，但其内在精神殊途同归，均难以认可瑕疵出资股东对债权人的责任承担享有顺位利益，与作为其实体规则渊源的《公司法解释（三）》存在矛盾。

（2）责任的有限性

所谓有限性，指的是瑕疵出资股东对债权人承担的清偿责任在范围上是有限的，具

[34] 参见张玉敏主编：《民法（第二版）》，北京：高等教育出版社，2013 年版，第 346 页。

中国知网 https://www.cnki.net

体表现为股东的数额利益，也就是在确保其承担的最终责任的数额上，股东具有抗辩权。

具言之，如果公司的资产超过其对外负债的数额，则瑕疵出资股东无需向公司债权人承担责任；当公司的资产净值小于负债时，公司无力清偿部分数额越大，瑕疵出资股东可能承担的责任就越大，其数额利益就越小，直至公司未清偿数额大于法律规定的瑕疵出资责任的最大范围，此时也就不存在数额利益了。

股东具有的数额抗辩属于绝对抗辩权，公司的清偿行为不会折损股东行使数额抗辩的效力，虽瑕疵出资股东最终承担的责任数额会根据公司的清偿情况发生变化，但是仍然只能在法律圈定的责任范围内“活动”。

股东责任的有限性乃公司法之根基，在这一点上实体规则与程序规则表现出一致的态度。但是，在责任范围的划定上，实体规则与程序规则又产生了冲突。《公司法解释（三）》规定股东在“未出资本息”范围内对债权人承担补充清偿责任，根据《变更、追加规定》，存在瑕疵出资情形的股东在“未出资”或者“抽逃出资”范围内承担补充清偿责任。换言之，实体规则所言之有限，指的是在“本金加利息”范围内的有限，而程序规则所支持之有限，仅及于“本金”范畴。

因实体规则认可的责任范围大于执行程序规则所确认的责任范围，使得径直在执行程序中追加瑕疵出资股东常常难以实现纠纷的一次性解决。换言之，经由不同的救济途径，承担补充责任的瑕疵出资股东，所需承担的责任范围存在差异：如果未参与诉讼阶段，于执行当中被径直追加为被执行人要求承担补充清偿责任的瑕疵出资股东，免于负担“未出资额利息”范围的责任。

最高法颁布《变更、追加规定》这一司法解释的初衷，在于通过执行追加把当事人从不必要的诉累中解脱出来，推动实体权利的快速实现，节约司法资源。但对于瑕疵出资股东对债权人所生之债权而言，因实体规则确认的责任范围大于执行程序规则确认的责任范围，当债权人通过执行追加的方式要求瑕疵出资股东履行清偿义务，该股东已以全部瑕疵出资金额向债权人履行债务后，债权仍然未获得完全实现，此时债权人仍有机会通过另行提起普通民事诉讼，请求该瑕疵出资的股东向其履行“利息”范围内的补充清偿责任。因执行程序规则与实体规则之间矛盾的立法，加剧了当事人的程序负担，与程序规则的初衷相去甚远，这也加重了《变更、追加规定》适用中的现实困境。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）资本认缴制改革提出新的挑战

公司资本制度改革后，认缴登记制下公司信用的外观标识被严重削弱甚至不复存在。资本认缴制下，除了金融机构、证券公司等特殊行业仍然实行注册资本实缴登记制外，其他的公司均施行认缴登记制，法律不再对公司注册资本的收缴数额、何时收缴以及收缴的股份百分比作具体的限制性规定，而是将权利赋予公司交由其自治管理，进一步弱化资本的担保功能，强化了资产的担保功能。

公司信用标识一般包括外在标识与内部标识，外在标示最主要的就是营业执照之记载，内在的标识主要为公司的资产状况和经营状况。公司的偿债能力归根结底是由公司现有的净资产及未来的盈利能力决定的，因而其内在标识才真正对债权人作出商业判断具有意义，但是，一方面，公司法未强制非上市公司公开披露其财务报表，公司当然也无主动披露的动机；另一方面，债权人无权介入公司治理事宜、参与公司经营事项，获知信息成本高昂且极易触发侵犯公司商业秘密的法律风险，加之公司的偿债能力由资产状况、负债比例等多方面的因素共同决定，资产状况变动不居、资产结构复杂、资产变现能力难以量化，使获取的信息的参考价值大打折扣。[35]

鉴于内在标识难以获取、难以鉴别，对于股东的瑕疵出资行为的认定，一般采外部的、表见的标准。具言之，在实缴制下，对于出资行为，一般以对外公示的营业执照为标准，存在实际缴纳出资数额与营业执照的记载不相符、未在规定期限内缴纳出资等即可认定为违反出资义务；对于抽逃出资行为，主要以验资报告为参照，在验资程序后转出出资的，一般可认定存在抽逃出资。上述二者满足其一，一般即可认定存在瑕疵出资行为，继而裁定追加该股东为被执行人。[36]

然认缴制改革后，外在标识的进一步弱化：营业执照不再必须记载实收资本额、强制验资程序被废除，而最大的冲击来自于股东登记时不再必须报备其出资额，
这一系列举措导致出资情况缺乏必要对照，上述认定标准的根基发生动摇、难以继续发挥成效。加之内部经营信息难以获知，相应披露制度尚未建立起来，且抽逃出资行为的实施本身就极具隐蔽性，于公司债权人而言，举证证明股东存在瑕疵出资行为更加不易。于执行法院而言，查清事实、明晰权利义务关系丧失了最为简单明了的判断标准，在审

[35] 参见袁碧华：《我国公司资本制度改革研究》，北京：中国政法大学出版社，2016 年版，第 100 页。

[36] 参见张欢、洪宁：“公司资本制度改革后股东追加执行的困境与突破”，《上海政法学院学报（法治论丛）》，2015 年第 6 期，第 116—122 页。

中国知网 https://www.cnki.net

查认定上需要耗费更多精力，可能要几经周折，多次“辩论”与“质证”才能理清事实、查明真相。《变更、追加规定》第 28 条第 2 款规定的公开听证程序，事实上常常成为了变相的庭审，这有违背执行的形式主义原则的嫌疑，成为了横亘在执行实务中的难题。

除出资数额上的瑕疵外，出资期限尚未届至的股东是否构成瑕疵出资，能否对其适用加速到期，何时才能适用加速到期，则给实践部门提出了更大的挑战。

3.程序规则与程序规则间的矛盾

程序规则是程序法理的外在载体。基于程序法理基础的争议重重，程序规定则与程序规则之间，自然也同样存在相矛盾、相冲突的现象。此处程序规则之间的矛盾直接源于法理基础上的争议，是理论争议的外在表现。

首先，根据当前司法解释的规定，代位执行规则与执行追加规则均可适用于对瑕疵出资股东的执行，规则的排除适用并非清晰明了。具言之，《执行规定（试行）》将瑕疵出资股东承担的补足出资责任视为“债务人的到期债权”，交由代位执行规则予以调整，通过向瑕疵出资股东发出“履行通知”，强制其向债权人履行到期债务；《<民诉法>解释》也持一致立场，单独确认了对被执行人到期债权的执行规则，具体操作层面也求诸于“履行通知”，根据该规则瑕疵出资股东负担的补足出资责任也属于被执行人的到期债权，通过向其发出“履行通知”，强制其清偿债务；《变更、追加规定》则要求遵照执行变更、追加程序规则，将瑕疵出资股东追加为被执行人，再于执行程序中强制其履行债务。

两种规则之间的根本差异，在于二者对于瑕疵出资的认定上采取了不同的态度：代位执行规则以瑕疵出资已得到法定程序认定为债务人的到期债权为前提，也就是代位执行规则本身不包含权利确认的因素，也不承担对实体问题判断失误的风险；而执行追加则要求在程序内对涉及的追加事由作出裁断，瑕疵出资的认定不可避免的包含实体问题，执行追加制度实际上负担了实体审查错误的风险，所以解释机关在执行追加程序中设置了实体性救济措施来防范上述风险。更为根本的矛盾，在于对瑕疵出资股东的执行中，执行追加规则负担了对实体问题判断，这对当前民事程序法关于执行的基本原则、执行权的配置、执行机构的配置等方面的规则产生了巨大的冲击。

综合上述分析，实体规则与实体规则之间面临部门立法与司法解释之间“双轨运行”

中国知网 https://www.cnki.net

的局面，程序规则与程序规则之间面临一般性解释与特别领域的解释之间的“错位”，程序规则本身又与实体规则之间存在天然的沟壑，二者总是难以达到完美协调的状态，因此，瑕疵出资股东的执行追加规则适用矛盾重重，在司法实践中之适用困难重重。

（三）程序操作问题重重

任何理论与规则上的小毛病，都会给具体操作留下大隐患、并且最终都会毫无遗漏地爆发出来。法理基础上争议重重、缺乏统一认识，必然导致规则的制定左摇右摆、冲突规范层出不穷，进而适用上左支右绌，具体操作中遭遇重重问题。

1.申请程序的问题

申请程序中的问题主要表现在程序启动的主体上，也就是执行追加应依当事人申请启动还是执行部门依职权启动，或二者兼宜。

可以依当事人申请启动自不待言，问题的焦点在于执行部门能否依职权启动执行追加程序。

现行司法解释认为执行部门不得依职权追加瑕疵出资股东为执行当事人。执行权具有司法权和行政权的双重效力属性在学界已经形成共识，司法权要求法院保持被动，行政权又赋予其采取主动行为的空间。在执行程序中，法院在特定范围内具有主动性，可以不经当事人的同意而主动采取某些措施，然对于瑕疵出资股东的执行追加，往往涉及当事人之间的实体权利义务争议，能否追加之判断应属执行裁判权的范畴，此时执行部门行使执行权时应恪守司法权的属性，保持被动和中立。因此，《变更、追加规定》对法院依职权启动程序持否定态度，也就是执行追加只能依据当事人申请而启动。

然而在实践中，由于信息的不对称，诸多可以变更、追加当事人的事由，往往是执行部门在具体开展执行措施时发现的，债权人对此不一定知情，此时执行部门就处于十分尴尬的境地。为解决执行机关“有实无名”，执行当事人“有名无实”的矛盾状态，发挥制度的实效，有学者主张以执行公开原则为依据，赋予执行机关以告知义务，为债权人获悉执行机关通过财产调查掌握的执行当事人变更、追加事由开方便之门。[37]司法

[37] 参见谭秋桂：“论民事执行当事人变化的程序构建”，《法学家》，2011 年第 2 期，第 131—139 页。

中国知网 https://www.cnki.net

实践中，也有部分法院持此看法。[38]

另一方面，如果认定对瑕疵出资股东财产强制执行之理论内核为代位执行，那么瑕疵出资股东的出资责任属债务人享有的到期债权，应落入执行标的范畴，根据强制执行法的基本原则，执行部门对执行标的的执行属于其职权、职责的范畴，鉴于此，执行部门是否应具备主动追加瑕疵出资股东为执行当事人的职权呢？

2. 审查程序的问题

司法解释机关在《变更、追加规定》第 28 条第 2 款[39]对执行追加的审查程序作出规定，该规定具体内容包括两个方面：一是对何时审查、由谁审查以及采取何种方式审查三个问题作出具体的程序安排；二是依据案件是否有争议对审查程序作出了区别规定，区别主要表现在审查主体、审查方式两个方面。

何时审查，也就是审查时机的问题，一般分为事前审查和事后审查两种。所谓事前审查，指的是在申请人提出变更、追加执行当事人的申请时，审查机关根据其所提交的书面证据材料，对其申请理由进行审查，理由成立则裁定追加，理由不成立则驳回申请。所谓事后审查，就是指在申请人提出变更、追加执行当事人的申请时，审查机关不对其申请的理由进行审查，只要其提交之申请材料形式完备，直接依据其申请立即作出变更、追加执行当事人的裁定，只有当申请追加的当事人或被申请追加的主体对其作出的追加裁定不服时，执行机关方对其申请变更、追加执行当事人的事由进行审查。事前审查重心在于预防，事后审查侧重于救济。

根据《变更、追加规定》，对变更、追加执行当事人的申请一律进行事前审查，以期为当事人及第三人提供更加周全的程序保障，因为在事前对实体法律关系进行审查的基础上作出裁定，有助于避免出现执行错误、损害当事人和案外人的实体权利。但是，事前审查不可避免的造成执行效率的低下，尤其是在事实清楚、争议不大的案件中，事前审查无端耗费了当事人和案外人的成本，甚至给部分狡猾的债务人转移财产的可乘之机。由于司法解释制定过程中缺乏充分的合法性论证，出台之规则必然需要“左右逢迎”，规定严格的事前审查，颇有些于执行追加救济中实现另诉审判救济诉求的意味，制度变

[38] 例如溧水县房产经营公司因未依法缴纳股东出资被追加为被执行人执行异议案，案号（2011）宁执异字第 31 号。

[39] 《变更、追加规定》第 28 条第 2 款规定：除事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的案件外，执行法院应当组成合议庭审查并公开听证。

中国知网 https://www.cnki.net

革的缓慢、渐进本不可厚非，然而在存在实体性救济程序的情形下，仍于事前展开过于严格的审查就显得有些冗余了。

接下来就是由谁来审查、以及采用何种方式来审查的问题。对于事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的案件，按照司法解释之规定，应该由执行人员来进行审查；除此以外的案件，则由执行法院组成合议庭，通过公开听证的方式进行审查。

至于审查方式，也就是选择形式审查还是实质审查的问题。形式审查，指审查主体根据申请人的书面申请及其提供的书面证据材料，不经过言辞辩论程序，通过书面审理的方式对其申请事由作出判断，形式审查的优点在于能够快速高效的作出判断，利于提高执行效率，但容易造成执行错误，因此往往需要与事后的实体性的救济措施相结合。实质审查，指的是审查主体除根据申请人的书面申请、提供的证据材料外，尚需经过“辩论”和“质证”环节听取当事人的意见，在此基础上可能还需结合其依职权调查获知的信息，作出综合判断。与事前审查相类似，实质审查在执行当事人变更、追加程序中能够最大限度地预防损害案外人和当事人的实体权益，防范错误执行，但是实质审查往往需要耗费大量的司法资源、造成执行的拖延，适用于无争议的案件则有些大材小用。

对于瑕疵出资股东的执行追加的审查方式，司法解释规定如下：首先需将案件分为“事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的案件”和不满足上述任一条件的其他案件，对第一类案件，解释机关倾向于进行形式审查，以敦促执行法院快速做出裁判，但也给执行法院留出了自行衡量的空间。对于第二类案件，“执行法院应当组成合议庭审查并公开听证”，也就是执行法院应当对此类案件展开实质审查，然于执行阶段进行实质审查饱受诟病，毕竟在制度提供了充足且容易接近的事后救济程序的情况下，执行法院对于执行追加的审查似乎无需过于小心翼翼，效率价值在此阶段应该占据绝对上风。

但是在实践中，当前社会对于执行效率低下尚能容忍，对执行错误的容忍度却极低，致使执行错误补救成本过于高昂，导致法院对于瑕疵出资股东的执行追加，倾向于不问事实是否清楚、权利义务关系是否明确、争议是否存在，一律采用实质审查的方式，组成合议庭并公开听证，审查程序在某种程度上履行了“庭审”的功能，成为了“变相的庭审”。

中国知网 https://www.cnki.net

3.裁判程序的问题

裁判程序上的困难主要源于实体规则与程序规则之间的矛盾，具体来说就是瑕疵出资股东对债权人承担责任的范围，实体法上的规定与与执行追加司法解释的规定不一致，导致执行追加的裁判左右为难、进退“失据”。

如前所述，《公司法解释（三）》第 13 条规定，瑕疵出资股东在“未出资本息”范围内对债权人承担补充清偿责任；《变更、追加规定》规定，存在瑕疵出资情形的股东在“未出资”或者“抽逃出资”范围内承担补充清偿责任。易言之，《公司法解释（三）》划定之“有限责任”的责任范围包括瑕疵出资的本金及其利息，《变更、追加规定》仅支持在瑕疵出资本金范围内进行强制执行。

但二者同属司法解释，解释机关均为最高人民法院，换言之，二者在效力上处于同一位阶层级，只是调整对象有所区别。执行法院若严格依据程序规则作出裁定，因实体规范所确认的责任限额大于执行规范认可的责任限额，当债权人申请追加执行瑕疵出资股东，要求其履行清偿义务时，该股东已以全部出资瑕疵金额向债权人履行债务后，债权仍可能未获得完全实现，则实体法赋予债权人的权利，实际上并没有得到完全实现，债权人在执行追加程序结束后，仍有机会另行诉讼对未得到完全清偿的部分提出请求，也就是执行变更、追加规则本身蕴含着与纠纷的一次性解决、效率价值相矛盾的内容。另一方面，若执行法院以实体规则为蓝本，在执行追加程序中作出责任范围包含瑕疵出资本金及其利息的裁定，那么又将面临僭越法律规定、裁定于法无据的责难。

此外，当债权未得到完全清偿时，债权人还能否另行提起侵权诉讼，主张利息范围内的债权呢？问题的核心在于部分请求是否受禁止重复诉讼规则的约束以及执行追加中的实体性救济程序与普通民事诉讼的关系，执行异议之诉中产生的判断对后诉是否具有既判力。

4.救济程序的问题

无救济则无权利，程序性救济与实体性救济各司其职、相得益彰，共同构成了民事执行救济的两个基本单元。引起程序性救济的原因在于执行程序存在瑕疵，一般为执行机构所为的具体执行行为失当，损害了当事人或案外人的合法权益，不涉及实体权利争议，当事人通过向上级法院提起程序性救济来矫正程序瑕疵，维护程序利益，并间接地

中国知网 https://www.cnki.net

保护其实体权益。引起实体性救济的原因在于当事人之间或者当事人与案外人之间就民事执行所涉及的实体权利义务关系发生争议，导致其对于执行程序是否应该继续或者应如何继续的问题产生分歧，当事人或案外人可通过寻求实体性救济，要求执行法院对于相关的实体权利义务关系作出裁判。

对于执行当事人的变更、追加，我国司法解释根据引起变更、追加事由的不同，分别赋予了当事人提请程序性救济和实体性救济的权利，也就是根据追加事由的不同，当事人只能向上一级人民法院提起复议或向执行法院提起执行异议之诉。换言之，《变更、追加规定》规定的救济程序，虽具有程序性救济与实体性救济两种方式，但具体该援用何种救济程序，并非根据当事人的异议事由决定，而是根据申请追加的具体情形来划分，根据瑕疵出资、人格混同、清算责任启动追加之情形，当事人只能寻求诉讼救济，其他情形只能求诸于复议。

根据司法解释的规定，追加执行瑕疵出资股东的程序中，当事人存在异议的均得提起执行异议之诉，不论异议内容为程序瑕疵还是实体争议，基于此，程序瑕疵要么救济无门，要么必须由执行异议之诉来解决、“大材小用”，显然如此的制度安排欠缺合理性。

三、瑕疵出资股东执行追加制度的基本法理

当事人是否适格的问题严重依赖于民事实体法的规定，程序法只能提供一个抽象的标准，但程序法的特别价值正好也在于给出一个抽象的标准，否则从浩瀚的实体法中选取判断适格当事人的具体标准是很困难的。

瑕疵出资股东执行追加的基本法理，需要直面重重争议，分别从程序法与实体法的角度回应争议、澄清误解，为解决规则适用中的矛盾和程序操作中的问题提供有力的理论支撑。

（一）执行力的主观范围扩张

首先应明确的是，对执行当事人的讨论就是对执行力主观范围的讨论。执行当事人，

中国知网 https://www.cnki.net

指的是依据执行名义确定的权利主体与义务主体，权利人，又被称为执行债权人，指的执行名义记载的实体权利的享有者，可以根据执行名义申请执行法院实施强制执行以实现权利；义务人，又被称为执行债务人，指的是依据执行名义，负有容忍执行法院对其施加的强制力的人。[40]执行力主观范围指的是执行名义的执行力所及于的主体的范围，一般也应限定于执行名义所载明的权利义务主体。二者并无本质差异，无非是执行力主观范围是理论上之概念，而执行当事人是立法上、实践中的表达。

1.执行力主观范围相对性原则

如前所述，债权人应如何向瑕疵出资股东主张权利，存在另诉审判救济与执行追加救济的争议，能否另诉寻求审判救济，关切的是执行名义的既判力的主观范围的问题，能否执行追加救济，关切的是执行名义的执行力的主观范围的问题。

既判力，也被称为实体的确定力，指终局判决对诉讼请求的判断是规范今后当事人之间法律关系的基准，当事人不得对终局判决作出的判断再行争议，也不能提出与之相矛盾的主张，法院不得作出与该判断相抵触的判决。[41]执行力，指的是为实现执行名义所命令的给付内容，而可以利用强制执行程序的效力。[42]

作为执行名义的终局判决旨在解决对立当事人之间的实体性纠纷，因而该执行名义所生之既判力，原则上仅拘束法院与对立的双方当事人即可，否则将有可能导致对第三人合法权益的不当干涉，一定程度上也剥夺了第三人的“接受裁判权”，这被称为既判力主观范围的相对性原则。

有原则就有例外。在特定情形下，案外第三人与本案诉讼标的产生密不可分的联系，如既判力不对其进行扩张，那么通过诉讼程序定纷止争的效果必然会打折扣，基于上述考虑，在某些特定的情形下，判决效力应划一性地扩张及于与案件具有利害关系的第三方主体，也就是所谓的“既判力主观范围的扩张”。[43]综观大陆法系国家和地区的理论研究成果与立法实践，判决既判力的主观范围主要在下述三种情形下发生扩张：一是向诉讼担当时之被担当主体的扩张；二是向诉讼系属后之权利义务继受主体的扩张；三是

[40] 参见杨与龄编著：《强制执行法》，北京：中国政法大学出版社，2002 年版，第 37 页。

[41] 参见[日]新堂幸司：《新民事诉讼法》，林剑锋译，北京：法律出版社，2008 年版，第 472 页。

[42] 参见陈桂明、范向阳：“不动产执行程序中执行力的扩张——兼谈执行法作为程序法对实体法的回应与干预”，《人民司法·应用》，2017 年第 21 期，第 101—107 页。

[43] 参见胡军辉：《民事既判力扩张问题研究》，北京：中国人民公安大学出版社，2011 年版，第 31 页。

中国知网 https://www.cnki.net

向争议标的物之实际持有主体的扩张。[44]

第一，向诉讼担当时之被担当主体的扩张。[45]在诉讼担当时，诉讼担当人是形式意义上的当事人，而被担当主体是真正意义上的实体权利义务关系主体，是隐藏着的当事人，是实际利益的归属主体，因此确定判决的既判力应该及于诉讼担当人和被担当人。如不认可其对被担当人有既判力，被担当人将有权就同一纠纷另行提起诉讼，导致已经为权益判断之事项再次系属于诉讼，既不符合诉讼经济原则，也易导致矛盾裁判。[46]

第二，向诉讼系属后之权利义务继受主体的扩张。指的是确定判决既判力扩张及于在诉讼系属后，基于法律之规定或约定，自当事人或者被担当之他人处继受实体权利、义务的第三方主体。[47]

第三，向争议标的物之实际持有主体的扩张。指确定判决对于诉讼系属后为当事人或其继受人持有争议标的物之人，亦受既判力扩张所及。因争议标的物之实际持有主体不具有自己固有的占有利益，而专门为当事人或其继受人的利益而持有，因此在与交付争议标的物请求相关的范围内，其可以被视为当事人，此时既判力向其扩张，既不会不当干涉其固有的实体权利、损害其程序保障利益，也有助于促进判决的迅速实现。[48]

根据上述分析，债权人取得的确认其对公司享有债权的胜诉判决，既判力仅及于债权人及公司，存在瑕疵出资的股东不在既判力主观范围扩张所及于的主体范围内，换言之，上述判决对债权人另行起诉股东、请求其履行出资责任不产生阻断力，债权人可以另诉寻求审判救济。

但是，已经进入到执行程序后，是否必须另行起诉，则与执行名义执行力的范围息息相关。执行力主观范围也须受相对性原则的约束，换言之，执行力原则上应限定于执行名义所载明的债权债务主体，尤其是在债务人的确定上必须小心谨慎，因涉及对其财产的强制处分，不得随意扩张其主观效力的范围。[49]然而基于高效化解纠纷、减轻不必要的诉累等特殊考量，执行力主观范围在特定情形下也有扩张之需要，当然也必须对扩

[44] 参见丁宝同：“民事判决既判力研究”，西南政法大学博士论文，2009 年，第 119 页。

[45] 诉讼担当，指本来不是民事权利或法律关系主体的第三人，为他人之利益而以自己的名义进行诉讼，所受判决的效力及于被担当主体的制度设计。诉讼担当包括两种基本形态：一是法定诉讼担当，指依据法律规定，将诉讼实施权授予实体法上权利义务归属主体以外的第三人行使的情形。二是任意诉讼担当，指第三人依据法律关系主体的直接授权取得诉讼实施权。

[46] 参见常廷彬：《民事判决既判力主观范围研究》，北京：中国人民公安大学出版社，2010 年版，第 87 页。

[47] 参见丁宝同：“民事判决既判力研究”，西南政法大学博士论文，2009 年，第 119 页。

[48] 参见常廷彬：《民事判决既判力主观范围研究》，北京：中国人民公安大学出版社，2010 年版，第 89 页。

[49] 参见陈桂明、范向阳：“不动产执行程序中执行力的扩张——兼谈执行法作为程序法对实体法的回应与干预”，《人民司法·应用》，2007 年第 21 期，第 101—107 页。

中国知网 https://www.cnki.net

张的范围加以严格限制，以防止执行力扩张中的专权和恣意裁断。[50]

关于执行力主观范围的界定，学界有两种看法，一种认为执行力的主观范围完全等同于既判力的主观范围，无另行规定执行力主观范围的必要；另一种则认为，二者并不完全一致，需要法律法规另行对执行力主观范围作出具体规定。[51]当前我国是通过颁布司法解释，具体划定了执行名义的主观效力的边界，其中股东瑕疵出资的情形被囊括在内，也就是说，司法解释认可了执行名义执行力向瑕疵出资股东的扩张。基于此，债权人所持执行名义的执行力扩张可及于瑕疵出资股东，也即如能经法定程序确定股东存在瑕疵出资，那么债权人与该股东之间的实体纷争即处于可强制实现的状态，不必经过审判程序获得新的执行名义。

问题在于关于股东是否存在瑕疵出资的判定，是否必须经由审判程序来认定。笔者认为，如果必须经由审判程序来作出判断，那么将彻底革除执行力主观效力范围扩张的实效性：一方面，执行力的扩张是由审判直接作用于执行，以省略对相关主体之间的权利义务提起新的诉讼。[52]而执行力主观范围能够扩张，其正当性在于实体关系的存在具有高度盖然性，因而可以通过相对简略的判断程序对实体关系作出裁决，在不损害公平的前提下，保证执行名义中确定的权利义务关系迅速得以实现，如果必须经审判程序方能认定瑕疵出资，那么执行追加将完全沦为“执行合并”，导致制度目的落空、实效大打折扣。另一方面，根据当前司法解释的规定，执行追加程序中对于是否存在瑕疵出资的判断并非终局性的判断，债权人以及股东均可随时提起实体性的执行救济，在赋予了事后的实体救济保障机制的情况下，首先通过执行追加程序作出判断，也能为公众接受。

2.执行力主观范围的扩张情形

如前所述，债权人在执行程序中向瑕疵出资股东主张权利，存在针对到期债权的代位执行与基于瑕疵出资的执行追加的争议，具体应由代位执行还是追加执行来解决纠纷、实现权利，关切的是代位执行的性质以及与追加执行关系的问题。

当前学界对于代位执行的性质的认识，主要包括“执行救济说”、“继续执行说”、

[50] 参见陈桂明、范向阳：“不动产执行程序中执行力的扩张——兼谈执行法作为程序法对实体法的回应与干预”，《人民司法·应用》，2007 年第 21 期，第 101—107 页。

[51] 参见常廷彬：《民事判决既判力主观范围研究》，北京：中国人民公安大学出版社，2010 年版，第 96 页。

[52] 参见刘学在、王炳乾：“执行当事人变更、追加的类型化分析”，《政法学刊》，2018 年 4 月，第 86—100 页。

中国知网 https://www.cnki.net

“协助执行说”、“债权保全说”和“执行措施说”，由于对代位执行性质的看法上的差异，导致对其执行名义也产生了不同的认识，主要包括“履行通知说”、“协助执行说”以及“原生效法律文书说”。[53]

关于代位执行的性质，笔者更赞同“执行措施说”，认为代位执行属一种执行措施，理由有三：第一，比较域外的立法例，德国、日本均将代位执行视为对其他财产权之执行的执行措施；[54]第二，我国《<民诉法>解释》第501条规定了代位执行，第500条为对搜查笔录的规定，第502条为对执行中财产权证照转移手续的规定，根据条文所处的位置，其前后均为关于具体执行措施的规定，可以推知解释机关把代位执行视为一种执行措施；第三，债务人的到期债权属于执行标的，对执行标的之执行手段应属执行措施。若代位执行性属执行措施，那么执行依据自然为原生效法律文书，也就是代位执行是对原执行名义确定的执行标的的执行。大多数学者认为代位执行的正当性基础在于执行力主观范围扩张，对被执行人到期债权的执行实际上应属于执行追加的情形，有学者指出，从执行力主观范围扩张的实质和依据看，执行被执行人的到期债权，实际上是原判决执行力向被执行人到期债务人的扩张，笔者深以为然。[55]

基于上述分析，代位执行作为一种执行措施，与执行当事人的变更、追加并非一个层面上的内容。执行当事人的变更、追加以执行力主观范围扩张理论为标准，旨在具体确定适格执行当事人的范围，进而明确执行标的的范围；而代位执行应用于对已纳入执行标的范畴或者案外人无异议的债务人到期债权的具体执行，关切的是执行措施具体如何选择的问题，属后一层面的问题，具体如图2所示。二者各有侧重，代位执行应以执行当事人的变更、追加为前提，二者本不存在非此即彼的紧张关系。

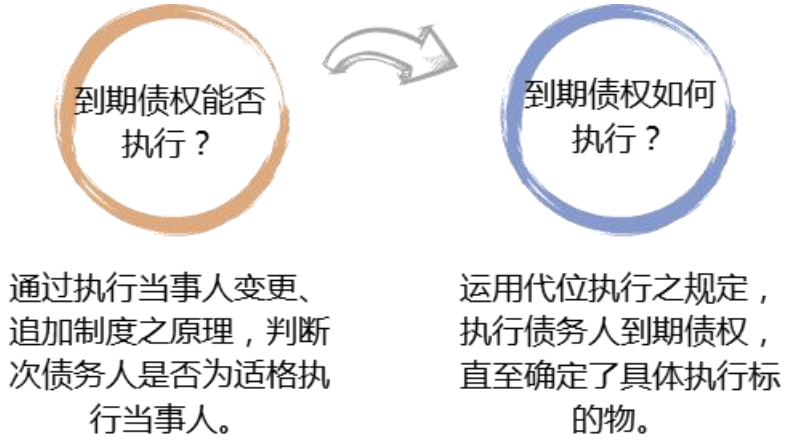
53 参见刘文勇：“再探代位执行程序的理论基础——从代位执行的执行依据及其正当性展开”，《民事程序法研究》，第十八辑，第95—108页。

54 参见武文浩：《代位执行制度研究》，郑州大学硕士论文，2018年，第11页。

55 参见常廷彬：《民事判决既判力主观范围研究》，北京：中国人民公安大学出版社，2010年版，第113页。

中国知网 https://www.cnki.net

（图 2：代位执行与追加执行关系示意图）



于瑕疵出资股东的执行而言，二者的根本差异，在于对瑕疵出资的认定上采取了不同的态度：代位执行规则以瑕疵出资已得到法定程序认定为债务人的到期债权前提，也就是代位执行规则本身不包含权利确认的因素，也不承担对实体问题判断失误的风险，其关切的是怎样最大化地实现已确定的权利；而执行追加则要求在程序内对涉及的追加事由作出裁断，而瑕疵出资的认定不可避免的包含实体问题，执行追加制度实际上负担了实体审查错误的风险，其关切的是能否对其执行、以及出现认定错误应如何救济的问题。应当说，执行追加涉及的是更为根本的问题，对瑕疵出资股东的强制执行，其理论基础也应在执行力主观范围扩张层面上讨论。

3.瑕疵出资股东追加的执行力渊源

如前所述，执行追加的基本法理在于执行力主观范围扩张理论，而进一步探讨瑕疵出资股东可被追加的执行力渊源到底为何，关切的则是既判力扩张与执行力扩张的关系问题。

执行力主观范围扩张与既判力主观范围扩张在理论上是一脉相承的。学界最初将执行力主观范围完全等同于既判力主观范围，也就是执行力主观范围以既判力主观范围为蓝本，且二者范围完全相同。有学者提出只要解决了既判力的扩张问题，执行力的扩张问题就迎刃而解，因为“就给付之诉的终局判决而言，有既判力就必然有执行力，执行力相对于既判力如影随形”[56]。但是伴随着强制执行理论研究的深入和司法实践的发展，

[56] 参见翁晓斌：“论既判力及执行力向第三人的扩张”，《浙江社会科学》，2003 年第 3 期，第 66—72 页。

中国知网 https://www.cnki.net

支付令、公证债权文书等非依权益判定程序获得执行力的执行名义出现，二者完全等同的观点难以为继，执行力扩张的范围不再完全受制于既判力扩张范围的约束。学界也逐渐跳出既判力扩张的框架，重新思考执行力主观范围扩张的正当性，但总体而言，多数学者还是认可执行力主观范围扩张借鉴了既判力扩张理论，执行当事人变更、追加的正当性基础仍然需要从既判力的角度来思考，二者应保持逻辑上的统一，因为“既判力是判决效力内容一个方面，既判力范围的扩张必然引起判决效力的扩张，而判决效力的扩张又必然导致执行力的扩张”[57]，但因既判力和执行力二者在制度趣旨和效力载体等方面的差异，学界也普遍认同执行力主观范围的扩张具有独立研究的价值。[58]

由于执行追加相关司法解释相继出台，尤其是2016年《变更、追加规定》这一司法解释的出台，学界又重新兴起了一股对执行力主观范围扩张作类型化研究的热潮。因执行当事人的变更、追加规则与《执行规定（试行）》、《<民诉法>解释》所指明之代位执行的立场似乎存在矛盾，加之司法解释出台后，解释机关也并未对执行变更、追加制度的合法性进行论证，导致对执行力主观范围扩张理论的研究，出现了许多颇具功利性、短视性的见解。

具言之，随着执行实务中面临的困境愈加复杂，司法解释中列举的执行追加事由更加多样，执行力主观范围扩张基本情形在某些情况下，难以提供“直接的”理论支撑，鉴于此，有学者提出执行力主观范围的扩张应分为两类：一是基于既判力主观范围扩张的执行力扩张，范围与既判力主观范围扩张完全相同；二是超出既判力主观范围扩张的独立的扩张。[59]第二类内部又包含“基于主体同一性”、“基于政策目的扩张”等扩张类型，以期将司法解释规定的追加执行的事由全部囊括在内。另有部分学者甚至跳出执行力主观范围扩张理论的框架另寻正当性基础，认为该理论不能解释司法解释涵盖的执行追加的全部情形，将司法解释列举的全部情形包罗进该理论中，是对理论的扩大解释、类推适用，不遵循理论的边界的行为，会导致理论解释力的稀释，使得执行力主观范围扩张理论漫无边际。并进一步提出，权利的具体实现与现实环境休戚相关，司法解释的拟定不仅要遵循理论逻辑的自洽性，还要着力于解决司法实践中的具体问题，就《变更、追加规定》认可的变更、追加事由而言，执行力主观范围扩张只能解释其中部分情形，

[57] 参见李浩主编：《强制执行法》，厦门：厦门大学出版社，2004年版，第166页。

[58] 参见刘学在、王炳乾：“执行当事人变更、追加的类型化分析”，《政法学刊》，2018年4月，第86—100页。

[59] 参见谭秋桂：“论民事执行当事人变化的程序构建”，《法学家》，2011年第2期，第131—139页。

中国知网 https://www.cnki.net

除此以外还有诸多其他类型的情形需要另寻其正当性基础。[60]

应当说，执行力主观范围理论与既判力主观范围理论，二者应保持“精神上的默契”，不能偏离太远。对于具有既判力的执行名义而言，执行力扩张的主观范围应当与既判力扩张的主观范围保持相对一致，对于其他执行依据，执行力扩张后的主观范围的确定也应该与判决效力理论保持理论基础上的统一性以及具体规则层面的融洽性。具体理由如下：一方面，因为执行力主观范围扩张是对民事诉讼基本命题的研究，论述的展开涉及到民事诉讼与民事执行的基本理论与基本制度，对于执行程序基本命题之讨论，必须采系统论的方法，从整个执行规则体系的宏观视野来思考，并且须与其他执行程序基本要素、基本规则配合考量。鉴于此，目前学界呈现的根据司法解释的规定，由果推因，并基于推定之结果量身打造新的分类标准，例如基于“主体同一性”的扩张类型，这种应急性的、功利性的做法是十分短视的，将给执行当事人变更、追加制度“撕开一条口子”，使得该制度完全沦为“政策目的”实施的工具，制度内在原理的统一性与逻辑的自洽性逐渐消失。另一方面，作为执行制度的基本命题，执行当事人的变更、追加制度最终的归宿应为“入典”，从民事诉讼法典的立法逻辑上看，条文之内容必须具有明确性和概括性：明确性要求其与民事诉讼法基本制度、基本理论之间相融洽，不存在与其他条文难以兼容的内容，换言之，应与既判力理论相溶融；概括性是指条文的体量必须收缩，同时法典的滞后性也要求条文本身具有更大的包容性，当前《变更、追加规定》所采取之列举式立法方式显然为“法典”所不能容忍，同样，超越既判力主观范围扩张的类型，另行创设的新分类标准也与法典的基本立场不相容，因其在创设之初即是因果倒置的，一旦面临新情况，必然包容性不足，难以保持长久的生命力。

必须强调的是，执行力主观范围扩张应与既判力主观范围扩张理论在逻辑上保持一致，并不意味着二者绝对的等同，这里强调的是普适意义上的一致，也就是执行力主观范围扩张在原则上与既判力主观范围扩张相一致，但因执行程序与诉讼程序在价值目标、制度理念、基本要素等方面的差异，必然存在少数例外情况，使得执行力主观范围扩张与既判力主观范围扩张不一致。例如，在实行执行文制度的国家，在执行程序启动环节，执行依据的外在标识发生变化，执行文与生效法律文书共同构成执行名义，因此需要对执行力扩张的分类进行调整。再如，因执行标的与争议标的物在执行程序与审判

[60] 参见刘学在、王炳乾：“执行当事人变更、追加的类型化分析”，《政法学刊》，2018 年 4 月，第 86—100 页。

中国知网 https://www.cnki.net

程序中地位的天壤之别，基于执行标的的影响，执行力主观范围扩张的具体类型划分需要在既判力主观范围扩张的三种类型的基础上作出调整。

具言之，笔者认为执行力主观范围扩张包括三类情形：一是向诉讼担当时之被担当主体的扩张；二是向诉讼系属后之权利义务继受主体的扩张；三是向执行标的之实际持有主体的扩张。

其一，向诉讼担当时之被担当主体的扩张。如前所述，在诉讼程序中诉讼担当人代表被担当人参与诉讼，被担当人作为实体权利义务最终归属主体，判决效力应向其扩张，应允许当事人申请追加其为被执行人。我国《变更、追加规定》第 2 条、第 10 条规定了关于遗嘱执行人、宣告失踪公民财产代管人等情形下的执行力扩张，一般被视为向诉讼担当时的被担当人的扩张。

其二，向诉讼系属后之权利义务继受主体的扩张。[61]当作为当事人的自然人死亡、法人消灭时，一般继受人得以概括性地继受原当事人的全部权利义务，此时执行力主观范围向一般继受人扩张，具体包括申请执行人的继承人与权利义务承受人、遗嘱执行人或者宣告失踪人的财产代管人、法人终止后的财产无偿接收人。特定继受指基于当事人的法律行为、法院的执行行为，继受原当事人特定的权利义务。[62]执行力主观范围能否向特定继受人扩张的问题在学界众说纷纭。持否定观点的学者认为，执行名义确定的实体权利义务关系，经过国家司法权介入调整，具备了实体性与程序性的双重属性，不得再允许当事人自由转让，因为程序权利不能因实体权利的转让而当然的发生转让的效果。[63]持肯定观点者则认为，生效法律文书所确认之债权与未经判决确认之债权，在性质上并无区别，在启动强制执行前，公权力未对其进行调整，只是经确认之债权受既判力的拘束，当事人不得再行争议罢了。笔者支持后者之观点，即执行力主观范围的扩张应当及于特定继受主体，因为“债权受实体法的调整是对的，但不能说债权本身要受程序法的约束”[64]，应当说审判程序调整的是债权的确认与实现，债权本身应由实体法来规范，程序法不应当、也无权干涉。我国现行司法解释也认可了对特定继受人的扩张，

[61] 当事人的继受人，是指依法承受当事人地位的主体，也就是继受判决确定的实体权利义务关系的主体。继受人可以分为一般继受人与特定继受人两类。

[62] 参见谭秋桂：“论民事执行当事人变化的程序构建”，《法学家》，2011 年第 2 期，第 131—139 页。

[63] 参见张卫平：“判决执行力主体范围的扩张——以实体权利转让与执行权利的获得为中心”，《现代法学》，2007 年 9 月，第 81—88 页。

[64] 参见张卫平：“判决执行力主体范围的扩张——以实体权利转让与执行权利的获得为中心”，《现代法学》，2007 年 9 月，第 81—88 页。

中国知网 https://www.cnki.net

例如《变更、追加规定》第 9 条规定了债权转让情形下，债权继受主体可以申请追加为申请执行人。综观《变更、追加规定》，我国强制执行实务中认可了执行力主观范围向当事人之继受人扩张的情形：第 1～9 条规定了追加执行债权的继受人为申请执行人的情形；第 10～12 条、第 22～23 条规定了追加继受人为被执行人的情形。

其三，向执行标的实际持有主体之扩张。此种类型之扩张是在既判力主观范围扩张的第三种类型的基础上作出调整，将“争议标的物”调整为“执行标的”的表述。

既判力主观范围扩张的第三种类型指的是，特定物权属争议的判决既判力扩张及于争议标的物实体持有主体，如前所述，既判力向其扩张不会损害其固有的实体权利和程序保障利益，因诉讼程序与执行程序顺序上的相继性，一旦启动执行程序，该特定物即直接作为执行标的，成为执行对象，执行名义执行力扩张及于该特定物之实际持有主体，成为案件的适格当事人。在特定物的权属争议中，诉讼程序中的“争议标的物”与执行程序中的“执行标的”具有共通性，这也是能够以此为基础上作出调整的前提。

但是，争议标的物与执行标的对于诉讼程序与执行程序而言，存在根本的区别，实现执行程序价值目标的，必须作出上述调整。具言之：

其一，争议标的物指的是当事人之间争议的实体权利义务关系指向的对象，一般仅存在于特定物的权属争议的给付诉讼中，概念之使用应限于特定的诉讼当中，审判终结后，争议标的物这一表述已显得不合时宜。关于执行标的，我国学术界存在多种不同的表述，大致分为三种：一是对象说，认为执行标的等同于执行对象；二是客体说，认为执行标的与执行客体相一致；三是混合说，将执行标的与执行对象和执行客体三者混同，认为三者含义相同。[65]笔者认为，执行标的与执行客体、执行对象三者内涵外延基本一致，均指债务人用于履行义务的财产或行为，无区别使用之必要。[66]审判终结进入执行程序后，争议标的物所指称之特定物，应落入执行标的的概念范畴，向执行标的持有主体扩张的表述方案更为严谨、合理。

其二，争议标的物概念外延过于狭窄、包容性不足。

执行标的包含财产和行为两方面的内容，关于执行标的的具体内容，台湾学者杨与龄提出执行标的包括五种：一是债务人现有之财产，二是债务人可取得之财产，例如到期债权，三是债务人虽已处分、但处分行为无效或者害及债权、债权人可申请撤销之财

[65] 参见李浩主编:《强制执行法》，厦门：厦门大学出版社，2004 年版，第 218 页。
[66] 参见田平安主编：《民事诉讼法学（第四版）》，北京：法律出版社，2015 年版，第 357 页。

中国知网 https://www.cnki.net

产，四是债务人所有但尚未进行所有权登记之不动产，五是限定责任之财产。[67]国内学者对于作为执行标的的财产内容的认识基本一致，具体包括四类：一是债务人的现有财产，二是债务人可取得的财产；三是债务人非法处分的财产，四是执行名义限定的财产。[68]“争议标的物”应属于“执行名义限定的财产”。根据民诉法及司法解释的规定，我国目前认可的、能够成为执行标的、结合具体执行措施对其进行执行的，包括：一是种类物，例如存款、以及债券、股票、基金等可变价的金融资产；二是特定物；三是债务人的到期债权；四是不动产等；五是特定行为。其中“争议标的物”一般仅指“特定物”。

争议标的物仅为执行标的项下的特定物这一种类型，如前所述，执行名义的执行力能够向作为执行标的的特定物的持有主体扩张，执行名义的执行力同样也能够向作为执行标的的其他类型财产或财产性权利的实际控制主体扩张，例如债权人申请对债务人的到期债权强制执行，也就是执行名义转作用于次债务人，实际上也就是执行名义执行力向次债务人发生扩张。[69]此外，即使在特定物权属争议案件的执行中，执行标的也并不总是限于诉讼中的争议标的物。因此，争议标的物或者说执行名义限定之特定物的概念范畴过于狭小，其上位概念执行标的外延更加周延，该种表述能够较为周延的概括此种类型的执行力主观范围扩张涉及的多样化的事由。

其三，审判程序和执行程序的价值目标不同，审判程序旨在对处于争议中的权利义务关系的现实状态作出判断，而执行程序的价值则在于对经确认的现实权益予以快速实现。对于判决确认的可金钱化的债权，所指向的财产范畴在执行程序中应扩大其逻辑外延，因为执行中“债务人的财产是债权人债权的总担保”[70]，债务人之财产，如为具有金钱价值之物或权利，原则上均得为执行标的。因此，执行力主观范围扩张的第三种类型应调整扩大外延范围，界定为向执行标的实际持有主体的扩张。

执行实践中，当事人或其继受人为逃避执行，常常在执行机关采取执行措施前，将执行名义所确定应交付之特定物转移给第三人占有，或者将其他属于执行标的的财产交由其他人占有，或者不积极主张其财产性权利，造成执行困难，为防止这种逃避执行的行为，有必要将执行力的主观范围扩张至实际持有执行标的的主体，在给付请求范围内，

---

[67] 参见杨与龄：《强制执行法论》，北京：中国政法大学出版社，2002 年版，第 41—43 页。

[68] 参见田平安主编：《民事诉讼法学（第四版）》，北京：法律出版社，2015 年版，第 358 页。

[69] 参见谭兆强：“论被执行主体之扩张”，《法律适用》，2011 年第 1 期，第 40—44 页。

[70] 参见赖来焜：《强制执行法总论》，台北：元照出版有限公司，2007 年版，第 410 页。转引自向国慧：《论执行力主观范围扩张》，西南政法大学博士学位论文，2014 年，第 50 页。

中国知网 https://www.cnki.net

对其持有的债务人所有的财产（包括财产性权利）进行强制执行，以保障实体权益的快速实现。《变更、追加规定》第17～19条规定的追加事由正是此种扩张情形的展现。

瑕疵出资股东的执行追加为第三种类型之扩张。对公司承担补足出资债务的瑕疵出资股东，也就是对公司负有到期债务，换言之，公司对其享有到期债权，一旦进入执行程序，该到期债权具有可执行性，应进入执行标的的范畴中，则瑕疵出资股东实际上成为执行标的实际控制主体，执行名义的执行力扩张及于瑕疵出资股东。

综上所述，《变更、追加规定》规定可以追加瑕疵出资股东为被执行人，理论基础在于瑕疵出资股东属执行力主观范围扩张所及之主体，具体来说，属执行力向执行标的之实际持有主体扩张。在此意义上，《变更、追加规定》与《执行规定（试行）》、《<民诉法>解释》对于瑕疵出资股东强制执行，其内在逻辑是一脉相承的，也就是将瑕疵出资股东视为债务人到期债权的持有人，因执行力主观范围发生扩张，股东受执行名义执行力约束，成为适格执行当事人，被追加进入执行程序，并对其进行强制执行。

（二）瑕疵出资的责任形态

因我国公司法及司法解释对于瑕疵出资责任的规定呈“双轨运行”的混乱局面，规则设定层面上的混乱也进一步导致了其在适用中的困难。

1.补充有限责任的批判

《公司法解释（三）》规定瑕疵出资股东对外产生补充有限责任，招致了多方面的诟病。

（1）司法解释僭越部门立法

依司法解释与被解释的法律之间的关系，应是“司法解释生长于法律文本”，诚如斯言：“解释者与法律文本之间的关系应当是一种服从与被服从、描述与被描述的关系，司法解释应遵从被解释对象的法律文本的权威，受解释对象的制约，负有忠实于解释对象的责任。”[71]环观《公司法》文本，《公司法解释（三）》构建之瑕疵出资股东对外

[71] 参见张志铭：“法律解释”，载于夏勇主编：《法理讲义》，北京：北京大学出版社，2010年版，第735页。转引自陈甦：“司法解释的建构理念分析——以商事司法解释为例”，《法学研究》，2012年第2期，第3—19页。

中国知网 https://www.cnki.net

生所生有限责任之补充性无法在《公司法》文本中找到“源头”，这应属于最高人民法院便于司法审判而作出之能动性、创设性的解释，有司法解释“立法化”的倾向。

《公司法解释（三）》对于瑕疵出资责任的规定，颇有几分“间接立法”的意味，笔者认为，司法解释应恪守本位，不能偏离原法律文本，解释机关在进行解释活动时，应尊重法律文本，维护法律的权威，不能随意的越过法律文本的界限，更不能离开具体的审判活动。

（2）补充责任无法自圆其说

股东对债权人之赔偿责任有别于侵权法以及担保法上的补充责任，将补充责任沿用于瑕疵出资的情形并不妥当。

补充责任这一责任形态最初产生于侵权责任法领域，《侵权责任法》第 37 条第 2 款[72]、第 40 条[73]分别规定了第三人介入时安全保障义务人承担补充赔偿责任，以及第三人侵权时未尽到管理职责的教育机构承担补充赔偿责任。补充责任，指的是一个侵权行为造成的损害事实产生了数个相重合的赔偿请求权，法律规定权利人必须按照先后顺序主张赔偿请求权，只有前顺位的赔偿义务人的赔偿不足以弥补损害时，才能请求后顺位的赔偿义务人赔偿。[74]《担保法》第 17 条规定的一般保证责任也属典型的补充责任。[75]

公司法上的瑕疵出资责任有别于上述补充责任，具体表现以下两个方面：第一，在法律关系上。侵权法上的补充责任与担保法上的补充责任的结构相同（如图 3 所示）：直接责任人因其侵权行为，给被侵权人造成损害结果，对被侵权人承担第一顺位的赔偿责任，补充责任人因其不作为而违反法定义务，对被侵权人承担与其过错相适应的补充赔偿责任，侵权法上直接责任人与补充责任之间无直接的债权债务关系，担保法上一般保证人可以在其履行范围内向债务人追偿。而公司法上瑕疵出资股东与公司、债权人之间的法律关系呈“链条状”：债权人对公司享有债权，公司又对股东享有补足出资的债

[72] 《侵权责任法》第 37 条第 2 款规定：因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；管理人或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。

[73] 《侵权责任法》第 40 条：无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间，受到幼儿园、学校或者其他教育机构以外的人员人身损害的，由侵权人承担侵权责任；幼儿园、学校或者其他机构未尽到管理职责的，承担相应的补充责任。

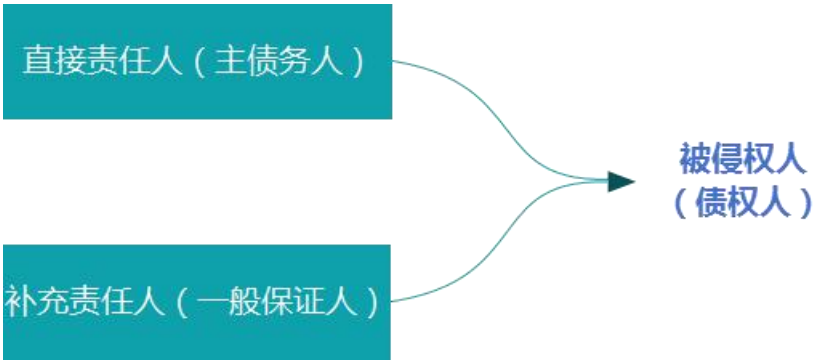
[74] 参见张新宝：“我国侵权责任法中的补充责任”，《法学杂志》，2010 年第 6 期，第 1—5 页。

[75] 《担保法》第 17 条规定：“当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。”

中国知网 https://www.cnki.net

权，股东与债权人之间本不存在直接的债权债务关系。

（图 3：侵权法/合同法上补充责任法律关系示意图）



此外，在责任成立与实现的顺序上。侵权法、担保法上的补充责任的成立以直接责任的成立为前提，《公司法解释（三）》规定的瑕疵出资股东对债权人承担的补充赔偿责任的成立以“公司不能清偿”为前提。侵权法、担保法上责任的成立与履行遵循如下步骤：①直接责任成立；②补充责任成立；③直接责任主体先对债权人进行清偿；④补充责任在直接责任履行不充分、不完全时才负担清偿责任，此步骤的发生具有偶然性。根据《公司法解释（三）》，瑕疵出资补充责任的成立与履行流程如下：①股东未适当履行出资义务，对公司产生补足出资责任；②公司对外部债权人负担债务；③公司不能清偿；④瑕疵出资股东对债权人产生补充赔偿责任；⑤补充赔偿责任的履行，此处瑕疵出资股东的履行，本质上是其出资债务的履行，其履行上具有必然性。

二者在法律关系及责任的形成与实现顺序上的区别，使得二者在执行阶段表现出巨大的差异，因瑕疵出资股东对债务人负担到期债务，且该债务在履行上具有必然性，导致瑕疵出资股东可被追加执行，而侵权法上的补充责任人显然不必承担此种风险。

（3）先诉抗辩挤压制度适用空间

另外，补充责任是一种基本的责任形态，补充性是基于责任形成上主次性与过错程度的大小，并结合民法公平原则的综合衡量，最终落脚于责任的承担上，先诉抗辩可谓是“补充性”的应有之意，顺位利益也就是享有先诉抗辩权，但是先诉抗辩权在当前对瑕疵出资股东的执行中显然没有生存空间，甚至其存在反而会阻碍执行程序的顺利推进。

如前所述，如果瑕疵出资股东对公司债权人所承担之责任具有补充性，将导致瑕疵出资情形下，变更、追加执行当事人制度完全没有适用空间。

中国知网 https://www.cnki.net

因为股东一旦主张先诉抗辩，债权人追加瑕疵出资股东为被执行人的申请将永远也无法得到支持。根据先诉抗辩的要求，债权人必须就主要债务人的财产先行提起强制执行，强制执行完毕其财产仍然不足以清偿时，方可向补充债务人主张权利。[76]一方面，对股东的追加必须以对公司强制执行完毕仍未获得完全清偿为前提，但是执行当事人的追加申请应发生于执行程序进行中，也就是应发生于执行进行中的程序需要以案件执行完毕为前提，显然存在逻辑上的悖论。另一方面，追加瑕疵出资股东的依据在于公司对其享有到期债权，如前所述，债务人的到期债权属于执行标的，如未对该执行标的进行执行，也无法达到“确无财产可供执行”的标准，执行无法结案，换言之，对债务人强制执行完毕这一前提根本就无法实现。

如果坚持瑕疵出资责任的补充性，那么其在执行程序中得到解决的可能性将会被彻底根除：既要实现充分的执行，又要保护被执行人的顺位利益，只能成为一个美好愿景罢了。

在传统大陆法系国家，补充责任的范围十分狭窄，但在我国司法实践中，补充责任在多个领域得到了迅速的扩张。[77]《公司法解释（三）》规定之补充责任，仅在责任的实现层面上具有补充性，这是一种功利性的解释，将瑕疵出资股东对债权人承担的责任认定为补充责任，至少是欠缺周全考虑的。

2.一般有限责任的回归

诚如斯言，“律者，常经也；条例，一时之权宜也”，笔者认为，部门立法与司法解释也应保持这样的关系。

公司法立法虽然在技术层面上存在许多问题，例如多抽象性表达、多原则性表述，使得法律的实操性差，但股东责任属于公司法基本命题，部门立法对于基本命题的立场必须坚持，也就是股东对外生一般有限责任属于公司法确定的原则性的内容，司法解释在该命题上应该保持谦抑，在坚持一般有限责任的基本立场的基础上，能动地为裁判者提供明确的适用标准、细化公司法的具体规定、填补公司法的制度缝隙，使得公司法立法与司法解释之间呈现一种紧密呼应的良性样态，而不是“双轨运行”的混乱局面。[78]

[76] 参见李中原：“论民法上的补充责任”，《法学》，2010 年第 3 期，第 78—91 页。
[77] 参见李中原：“论民法上的补充责任”，《法学》，2010 年第 3 期，第 78—91 页。
[78] 参见荣振华：《<公司法>立法与司法解释互应影响之研究》，北京：清华大学出版社，2018 年 7 月版，序言

中国知网 https://www.cnki.net

鉴于此，瑕疵出资责任应回归部门立法的基本立场，也就是瑕疵出资对内产生到期债权，对外呈一般有限责任。

综上所述，瑕疵出资对内产生到期债权，属于债务人的到期债权，应被纳入执行标的范畴。瑕疵出资对外所生之一般有限责任，使瑕疵出资人成为到期债权的持有主体，进而被执行名义的执行力所及，可对其追加执行。

（三）执行追加的制度价值

追加执行瑕疵出资股东之所以能为人们所接受，并在实践中取得成效，重要原因在于该种情形的执行力主观范围扩张具有坚实的实体法基础和程序法价值，也即具有正当性。

1. 实体法之秩序维护

实体法上的正当性，在于实体权利义务关系的存在具有高度可能性，故追加第三人使其进入到强制执行程序中，不致于破坏实体法所反映和体现的社会公平正义。[79]另一反面，只有义务主体切实履行义务，才能够彻底解决纠纷、现实地恢复实体法秩序。

追加存在瑕疵出资行为的股东，要求其向债权人履行清偿责任，本质上是债权人代位权在公司法上的表现。作为执行债务人的公司怠于行使权利，致使其资力不足以清偿，债权人以保全债权、防止债务人消极地减少其责任财产为目的，向瑕疵出资股东主张债权，要求其补足出资，也就是要求次债务人直接向债权人履行清偿义务，履行完毕后，股东在其清偿范围内的内部责任消灭，也即代位权的行使使得债权人与债务人、债务人与次债务人之间的债权债务关系消灭，而代位权行使的结果归于债权人。因此在公司无力清偿执行名义确定的债务时，追加执行瑕疵出资股东，符合实体法之规定，与实体法秩序相契合。

如前所述，公司法是一部渗透着浓烈公法色彩的私法，一方面其尊重契约自由、尊重股东的自治，体现私法的本质，但另一方面公司法在保护市场交易的安全可靠、控制投资风险、均衡保障股东、债权人及公司利益相关者上，发挥了重要作用。在当前实践

部分。

[79] 参见常廷彬：“试论执行力主观范围的扩张”，《法治论坛》，2010 年第 1 期，第 203—215 页。

中国知网 https://www.cnki.net

中，资本认缴制加剧了股东与债权人之间利益失衡的状况，债权人的弱势地位更加凸显，如果没有相应的应对机制，那么将极大地提高公司的融资成本、交易成本，因为于债权人而言，想要保全自身的利益，退出交易恐怕是最好的选择了。[80]因此，公司法必须重视对债权人的保护，着力构建常态化、规范化的债权人保护机制，这是公司制度的根本，无论如何都不能动摇。规范股东出资、责令瑕疵出资股东对公司债权人清偿出资，就是倾斜保障债权人利益的有力手段，而在执行程序中直接追加瑕疵出资股东为被执行人，为公司债权人快速高效地实现权利提供便捷的通道，则更是契合了公司法保护债权人利益的价值目标、呼应了实体法秩序的内在要求。

在当前实践中，市场中运作不规范的中小规模公司占大多数，公司有限责任呈现被严重滥用的态势，出资瑕疵、抽逃出资等问题频发，然而公司债权人在纠纷当中往往处于极为弱势的地位，如果不顾这种现实困境，执行程序将会寸步难行，甚至执行行为的实施在某种程度上给股东转移财产、逃避执行起到了“闹铃”的作用，可能将执行程序推上风口浪尖。因此，在公司股东存在瑕疵出资的情形下，对执行力的主观范围进行扩张，是维护实体法秩序的当然要求。

2.程序法之效率追求

程序法上的正当性，在于对执行程序公平理念的贯彻与对效率价值的遵守。强制执行程序的功能，在不损害债务人合法利益的前提下，保障经法定程序确认的债权充分、迅速实现，其中保障债权人的利益应为执行程序的首要任务，如果强制执行不能有效地实现债权，势必会导致公众对公力救济的不信任。基于此，较之公平、公正价值，强制执行程序更应在提升效率、真正实现债权上下功夫，

对价值的追求必须落实到强制执行的各个环节。首先在基本制度和具体规则的设计上，就应当避免烦琐，强调推动程序的迅速展开和措施的高效实施，当然同时也需要注意维护司法尊严、体现必要的人道价值。

以执行力主观范围扩张理论为基础搭建的执行追加制度，省略了非必要的审判对时间和资源的耗费，缩短了权利确认到权利真正实现间的等待时间，毕竟“迟来的正义非正义”在执行中也是适用的，另一方面，执行追加有利于缩减执行成本、避免债务人拖

[80] 参见袁碧华：《我国公司资本制度改革研究》，北京：中国政法大学出版社，2016 年版，第 101 页。

中国知网 https://www.cnki.net

延或者逃避执行、推动实体权利高质效地实现。但是必须注意对效率价值的追求也不能凌驾于公平正义之上，第三方主体能够为原执行名义效力扩张约束，需要具备三个条件：其一，原执行名义产生之程序合法正当；其二，提供充分的救济途径，确保案外人合法利益不受损害；其三，人民法院对申请进行审查，以避免案外人被当事人恶意拖入执行程序，并保障社会公共利益不受损害。

执行追加在平衡效率与公平上独具价值，形式化、外观主义的审查程序与周密的救济程序首尾呼应，对于从外观上、形式上足以判断第三人享有实体权利或应承担实体义务的主体，如果一味地要求通过诉讼或者仲裁程序来严密地保障当事人的程序性权利，易导致执行程序的效率低下，此时可以通过相对简略的、非庭审化的程序予以审查，迅速形成判断，同时，在裁定准许或驳回追加执行当事人的申请后，赋予相关主体提起事后救济的权利，为当事人之间的程序性争议和实体性争议分别提供了相应的救济渠道，充分地保障当事人的正当权益。

对于瑕疵出资股东的执行追加而言，根据债权人之申请，执行法院通过一个简略的听证程序听取当事人的陈述辩论，在审查判断的基础上迅速做出裁定，并给予被申请追加为执行债务人的股东和申请人提起执行许可之诉的权利。在执行追加程序中，当事人获得的程序保障，虽没有针对瑕疵出资股东另行起诉获得新执行名义的诉讼程序的保障充分、周密，但如前所述，瑕疵出资股东并非既判力扩张及于的主体，在执行追加程序启动前，并不阻碍债权人选择诉讼的方式来解决争议，执行追加只是给债权人提供了一种多元化的安排与选择，从此种意义上看，瑕疵出资股东执行追加程序所提供的程序性保障已经合理且充分。

四、瑕疵出资股东执行追加程序的规则完善

“司法改革无论如何冠冕堂皇，总是基于积案的压力”[81]在我国的司法实践中可谓是奉为圭臬，制度的变革总是以功利性的解决实践中的问题为第一要义。基于此，我国司法改革的首要目标是增强制度的实效性，在此基础上，再对制度变革可能产生的问题进行创设弥补（救济）措施，在此意义上，达成制度设计上的完整与制度实施上的“安

[81] 参见傅郁林：“繁简分流与程序保障”，《法学研究》，2003 年第 1 期，第 50—62 页。

中国知网 https://www.cnki.net

全无虞”。执行当事人变更、追加制度也不例外，其制度的设计自然受该宗旨的影响，也是“功利主义法学”的产物：综合该解释出台的背景以及在实践中适用的过程，执行当事人变更、追加规则，体现出强烈的“行政性”色彩，先将当事人追加进来，再考虑出现追加错误时，应如何补救，追求之目标实际上是“追加上的效率”与“救济上的公正”，是一种错位的效率与公正的平衡。

而德、日等国则更多地受注释法学派的影响。制度的变革，正当性论证先行，在现有制度的框架下进行合理正当的有益探索。至于执行当事人的变更、追加，德、日、韩适用执行文制度予以解决，在具体执行案件启动前，通常需依据债权人之申请启动执行文赋予之诉，以诉讼庭审化的途径先就能否追加问题予以裁判，也就是在执行当事人的变更、追加中，遵循“诉讼先行”的理念，换言之，在涉及实体权利义务争议的案件中，民事诉讼或者执行程序中的任何制度，在每一个阶段、每一个层面都强调“公正”，在此基础上，力求高效。

制度设计上的理念差异，导致了具体规则设计上的不一致，因此，德、日、韩的执行文制度，对于我国的执行当事人变更、追加制度有借鉴意义，但更需要根据我国司法解释规定和司法实践的状态作出相应的变更，进行“本土化”改造。

由于在司法实践中，股东瑕疵出资问题较为突出，司法解释明确其可以通过执行追加来予以解决，起到了一种指引的作用。对于瑕疵出资股东清偿责任的承担而言，因其涉及实体权利义务关系，若不存在争议，通过执行追加程序迅速实现实体权利，有助于执行程序目的的实现，提高执行效率，另一方面在执行程序中处理无争议案件，有助于一次性解决纠纷，节约司法资源；产生争议时，则通过设置实体性的救济程序，债权人与被追加的瑕疵出资股东均具有提起执行异议之诉的权利，审判机构仍然把握纠纷的最终裁决权，实质上仍然迂回的提供了诉讼程序的保护。此外，在执行追加程序启动之前，债权人也可以直接向有管辖权的人民法院起诉，要求存在瑕疵出资的股东向债权人承担补足出资的责任，之后持胜诉判决再行申请强制执行，在存在多元化的路径选择的情况下，有必要对不同的方式进行优化，在功能上将其区分开来，达到程序分流的目标。

鉴于此，笔者认为，可以把瑕疵出资股东的执行追加程序分成两部分来进行考察：将申请、审查和裁定三个步骤作为一个整体，称之为狭义的执行追加程序，将救济程序从执行追加中剥离出来，以此来优化瑕疵出资股东执行追加程序的制度安排。具言之，

中国知网 https://www.cnki.net

在申请、审查与裁定阶段，遵循形式化原则、外观主义原则，执行部门根据权利的外观形式进行审查判断，优先考虑效率价值的实现；一旦进入救济程序，则更看重公平正义价值的实现。一方面使得狭义的执行追加程序更加纯粹化，在有事后救济程序提供严密的保护下，可对现行规定作出更符合执行形式主义原则的调整，以促进执行追加制度效率价值的实现；另一方面有助于执行权与审判权的良性运转，促进诉讼制度与执行制度之间的功能优化配置。

但是原则理念和价值目标都必须依托于具体的制度设计才有实际意义。

（一）申请程序的规则完善

对于瑕疵出资股东进行执行追加，要求其向债权人承担补充清偿责任，应严格遵循以当事人申请为原则的前提要件。

如前所述，执行追加强调能否对特定主体进行强制执行的问题，对瑕疵出资股东而言，必然涉及对实体问题的裁断，在执行程序中对实体问题进行审查判断属于执行裁判权的内容，具有准司法权的特征，要求执行机构恪守被动性，因而执行追加程序的启动只能根据当事人的申请，执行法院不得依职权主动追加，即使当事人明知公司股东出资上有瑕疵而不申请追加的，也应充分尊重当事人的自由意志，视为当事人对其私权的处分，执行法院不应主动干预。[82]

申请主体上，司法解释仅赋予了申请执行人提出追加申请的权利，具体到本论题所讨论的案件类型中，“申请执行人”也就是公司的债权人，债权人可以根据实体法赋予的权利申请追加瑕疵出资股东自不待言，需讨论的是作为执行债务人的公司能否在执行当中申请变更、追加对其存在出资义务的股东为被执行人。笔者认为不应赋予公司以申请权，因为债权人对公司的外部性使其处于弱势地位，获取公司的真实信息往往需要付出高昂的成本，因此，当债权人能够提供充足的书面材料，并且能够达到经过书面的审理即可推论股东存在瑕疵出资的程度，程序法应对其提供适度倾斜的保护，是为其“为权利而斗争”的奖赏，在宏观上也有助于促进权利的迅速实现和实体法秩序的恢复。但是，公司掌握股东瑕疵出资的证据材料根本不费吹灰之力，如果赋予其申请执行追加的

[82] 参见魏锋：“执行当事人研究——一执行力主观范围扩张为中心”，中国政法大学博士学位论文，2009 年，第 94 页。

中国知网 https://www.cnki.net

权利，则无疑是为其提供了逃避执行、拖延执行的借口，对执行程序的开展、实体权利的实现无疑是雪上加霜。鉴于此，追加执行瑕疵出资股东的申请人只能是执行债权人。

最后，在申请阶段，需要在代位执行与执行追加之间设置一个传导机制，因二者靶向不同，解决的问题不一致，但根据当前司法解释之规定十分容易产生混淆，因此，对于当事人的申请，应基于瑕疵出资问题是否经法定程序认定，而分别流向不同的程序：未经确认的，应进入执行追加程序；已获得仲裁裁决、公证文书等法律文书的支持的，则应直接进入代位执行，无需再申请执行追加。

（二）审查程序的规则完善

对于债权人提出的追加瑕疵出资股东为被执行人的申请的审查，主要从两个方面着手来优化程序设置：一是审查主体的问题，二是审查方式的问题。

1. 审查主体

审查主体，也就是由谁来审查的问题。按照当前司法解释的相关规定，追加执行瑕疵出资股东的申请一般由执行法院组成合议庭来进行审查。笔者认为，在明确赋予了当事人相应的实体救济权利的情况下，由原执行案件的执行机构负责审查更为合理。因为：其一，瑕疵出资股东执行追加的价值在于，基于执行力主观效力范围扩张的影响，特定范围内的第三方主体直接成为适格的执行当事人，法院可直接对其实施执行行为，而不必经审判程序取得新的执行名义，从而使原执行名义确定的执行债权得到快速实现，最大限度地实现执行程序的迅速和经济，如果将其交由合议庭来审理，无异于否定了执行追加制度存在的价值；[83]其二，对股东是否存在瑕疵出资，原案件执行机构经过财产调查等一系列措施后，对公司的财产状况、股东的出资情况一般都了如指掌，由执行机构来审查，有利于避免作出错误判断，且更有利于推进执行顺利进行，推进纠纷彻底解决、案结事了。

有学者提出执行当事人适格审查的担当机关应为执行立案部门，因立案“有负责受理执行案件之职，且对于不能提供证明执行当事人适格相关证据的的执行申请，有裁定

[83] 参见魏锋：“执行当事人研究——一执行力主观范围扩张为中心”，中国政法大学博士学位论文，2009 年，第 95—96 页。

中国知网 https://www.cnki.net

不予受理的权力”[84]，实际上此种观点也是将审查主体限定于执行机构，隶属于执行权的实施。但是瑕疵出资股东享有数额抗辩的权利，仅对当事人是否适格作出的审查决定缺乏可实际执行的效果，另一方面，根据债的代位制度，代位权的行使以债务人怠于行使债权的行为对债权人的债权构成损害为前提，也就是存在无力清偿的可能性，基于此，追加瑕疵出资股东仍需要对公司的偿债能力进行评价，执行立案部门显然难以胜任，而执行机构通过财产调查程序，对公司的资产状况应当充分了解，因此对瑕疵出资股东的追加，由执行机构审查更为合理。

2.审查方式

首先应明确需要对执行追加申请进行事前的审查。如前所述，当前司法解释规定对追加瑕疵出资股东的申请，由执行机关主动展开事前审查，通过相对严格的审查方式，希望给当事人和案外人提供更为周全的程序保障，因为经事前审查作出的裁定，在对事实和法律根据进行审查判决的基础上，再实施执行行为，有助于避免出现执行错误、损害当事人和案外人的实体权利。

对于执行追加的申请，事前有审查的需要，原因如下：一是涉及当事人之间的实体权利义务关系，有防范错误之必要；二是瑕疵出资股东承担责任的有限性，有具体确定责任范围之需要；三是防止诚信善意的股东被无端卷入执行程序中。执行追加涉及执行名义外第三人的实体权益，在审查时机上，对其提供充足保障的价值应高于对于执行效率的追加，而事前审查的预防功能应处于首要，对于效率价值的兼顾，可以通过审查方式等其他手段来予以倾斜设置。

至于运用怎样的方式来审查，笔者认为，审查的具体方式根据审查事由的不同而有差别。对于瑕疵出资股东与债权人之间的实体法律关系，应以形式审查为原则。

具体来说，对于当事人之间的出资法律关系，原则上应采用形式审查。从执行当事人追加的制度设计的初衷出发，应当侧重于执行程序的效益和效率价值，且执行机构在执行追加问题中作出的裁定不具有终局的效力，有关利害关系人还可以随时提起执行异议之诉寻求充分的救济，在这种情况下，严格的审查方式显得冗余，没有必要一味地要求执行机构必须进行公开听证的方式来进行审查，且事前进行严格的审查不可避免的造

[84] 参见马登科：《案外人救济制度》，北京：法律出版社，2016 年版，第 232 页。

中国知网 https://www.cnki.net

成执行效率的低下，对当事人和案外人的时间、成本的无端耗费，甚至给部分狡猾的债务人转移财产的可乘之机，因此原则上进行书面审查即可。但是瑕疵出资股东的执行追加毕竟有其特殊性，对其审查判断不可能绕开实体权利义务关系，因此，在相关当事人要求陈述意见时，可以听取其意见。

另外，形式审查也要求审查范围不能超越一定的界限，如果允许对瑕疵出资股东执行追加的申请采取无限制的审查，将模糊执行审查与诉讼审理之间的界限，从而超越执行名义执行力扩张的范围。[85]

当然，以形式审查为原则并不意味着放宽了追加执行瑕疵出资股东的条件。司法解释赋予债权人直接申请执行追加的权力，意图在于给权利义务关系不存在争议的债权人，一个高效便捷的一次性解决纠纷、实现债权的“绿色通道”。因此，申请人所提交之书面证据材料不能形成股东存在瑕疵出资的大致推论的，不宜裁定准许直接在执行程序中追加股东为被执行人，其应先通过诉讼程序或者执行异议诉讼确认权利。对于股东出资不实、抽逃出资或转让瑕疵股权事实状况复杂的，或者对股东追加可能造成较大影响的，也应当采取更为谨慎的态度，应力求书面证据材料达到充分证明、或形成内心确信，否则裁定驳回其申请为宜，并告知其可提起执行异议之诉，在诉讼中对当事人之间的权利义务关系获得终局性判定后，再进入强制执行程序。

（三）裁判程序的规则完善

1. 裁判标准

资本认缴制下，《变更、追加规定》确认可被追加执行的“未缴纳或未足额缴纳出资”的股东能否涵盖未届出资期限的股东，引起了广泛的争鸣，学界对能否对出资期限尚未届满的股东主张加速到期存在两种不同的观点。

“赞成说”认为认缴制下可以对此作扩张解释，认为其规定中之“股东”包括出资期限尚未届至的股东，可适用加速到期要求其提前承担出资责任。因认缴制改革实际上是对 2005 年公司资本制度改革的继承与发展，在分期缴纳的基础上继续推进一次认缴、

[85] 参见参见张欢、洪宁：“公司资本制度改革后股东追加执行的困境与突破”，《上海政法学院学报（法治论丛）》，2015 年第 6 期，第 116—122 页。

中国知网 https://www.cnki.net

分次实缴制改革，可分期、分次缴纳注册资本是出于体恤创业之艰、鼓励投资兴业、避免资金闲置而对股东给予的特别呵护，但是公司一旦出现无力偿债的情况，表明股东之间关于缴纳期限的契约不当的损害了公司的偿债能力，进而损害了债权人的利益，也不存在被闲置的资金，此时公司法必须挺身而出，展现其强制性、公法性的一面，要求未届出资期限的股东提前缴付出资。如果该条规定未包含追加未届出资期限股东为被执行人之意，那么股东的期限利益与债权人的合法权益之间的冲突将进一步激化，强制执行法作为权利实现规范的职能大有落空可能。因此对于未届缴纳期限的股东，当公司资产不足以清偿执行债务时，出资期限应当加速到期，债权人可申请追加执行股东。

“反对说”则认为，认缴制下，公司法授权股东自行商定缴足出资的期限，法律不再强行干预，公司章程事实上成为了约束、规范股东出资的“规章”，如果股东不存在违背章程规定、不适当履行出资义务情况，要求股东提前履行出资义务于法无据、于理有亏。如果认可追加执行未届出资期限股东，要求其提前履行相应出资义务，无疑加重了公司股东的责任，在缺乏立法明确规定的情况下，显然不妥。且本次《公司法》修改着力于降低门槛、激发投资活力，通过系列举措为股东减压卸力，如允许对未届出资期限的股东适用加速到期，要求其提前向公司债权人承担责任，有与公司法修法目的相违背之嫌疑。

笔者认为应采纳前一种观点，也就是“赞成说”的观点，因为资本实缴制与资本认缴制之间的差异更多表现在公司设立阶段，也就是设立阶段不再要求满足最低注册资本要求、不再要求实缴资本达到一定比例、不再必须经过验资程序等，资本制度的变革，实际上是公司资本信用向资产信用演变的表现，注册资本表示公司信用状况的能力进一步弱化，转而强化公司资产在整体上显示的公司的实力，该模式下，强化了对资本的后端控制，更加强调设立后的市场监督和公司的信息公开、信息披露，通过动态的、不断更新的报表来展示公司的信用能力，交易相对方也基于此对交易风险作出判断。在此意义上，笔者认为，认缴制下，股东的出资责任，只有在公司经营出现问题的情况下探讨才有意义。换言之，在缺乏注册资本前端控制的情况下，幸运的投资者“空手套白狼”也是可以成功的，虽然投资者初始投入资金不足，但如果公司运转良好，业绩蒸蒸日上，债权人也是可以得到足额清偿的，那么没有必要过问股东的出资是否到位；一旦“空手套白狼”者出师不利，与债权人发生纠纷，存在经合法确认的、可强制执行的债务，此

中国知网 https://www.cnki.net

时，如果进入执行程序，必然是公司届期未主动履行或无法履行债务，在公司陷入支付不能的境地时，对于未届出资期限的股东应立即适用加速到期，而不再保护章程约定的“认缴期”。

其次，在强制执行中对于未届出资期限的股东适用加速到期也与资本制度改革的目标相契合。在公司设立阶段，简化公司设立程序，充分尊重股东的自治，进一步“激发创业活力，催生发展新动力”[86]，引导更多的主体走进市场，在良性运转的态势下，不干预市场主体的选择；同时，加快建立健全信用体系，强化信息公开和市场监督，股东的出资是公司资产的构成部分，因瑕疵出资的“去罪化”，民商事法律规制出资问题的责任理应更重了，事后的追究机制也与民商法的理念相契合。

最后，认缴制下，股东在出资金额及出资期限上具有充分的自由，许多股东都通过公司章程约定过长的缴付期限，例如部分“无赖公司”章程约定了二十年甚至更长的缴付期限，使得公司资产过于贫瘠，加之我国社会信用体系和诚信制度尚未建立起来，使得对这些“无赖公司”的强制执行更加棘手，为防止执行名义彻底沦为“一纸空文”，对于规定了不合理的超长出资期限的股东，应在执行追加中突破其约定之“出资期限”，准许对其适用加速到期制度，剥夺其期限利益，以惩治其不诚信行为，防止股东权利滥用之风的滋长。[87]

2.裁判形式

对执行当事人变更、追加的裁判，应一律使用裁定的形式。[88]

一方面，不能使用判决。因为虽执行当事人的变更、追加往往涉及当事人之间的实体权利义务关系，但其本质上仍属于执行裁判权的作用范围。[89]执行机构审查后作出的判断，仅仅解决在执行程序上能否变更、追加当事人的问题，而不对实体权利义务关系作出判断，审查判断结果仅具有程序法上的效果，不具备实体法上的效果。并且做出审查决定的机构为执行机构、非审判机构，无审判权，自然也无权做出判决。这也在一定程度上，缓解了未经权益判定程序直接于执行程序中作出裁判的尴尬，避免了诉讼法基

[86] 参见《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》（国发［2014］7 号）。

[87] 参见许金鑫、李美：“追加未届出资期股东为被执行人探析——以完全认缴资本制下股东提前承担出资责任为视角”，《法院改革与民商事审判问题研究》，全国法院第 29 届学术讨论会刊，第 706—714 页。

[88] 参见张卫平、任重：“案外第三人权益程序保障体系研究”，《法律科学（西北政法大学学报）》，2014 年第 6 期，第 132—140 页。

[89] 参见谭秋桂：“论民事执行当事人变化的程序构建”，《法学家》，2011 年第 2 期，第 131—139 页。

中国知网 https://www.cnki.net

本理论的责难。

另一方面，也不宜使用决定。因为瑕疵出资股东的执行追加有其特殊之处，因责任的有限性，对能否变更、追加的裁定必然包含对责任范围进行认定的内容，也就是必然涉及对实体权利义务关系的判断，而决定这一文书在内容上不应包含对实体权利义务的判断，因此，也不宜使用决定。

综上，内容包含实体性内容、效力上仅具有程序法上的效果，宜通过“裁定”的方式公开其审查结果。

3.裁判效力

鉴于前述，对于裁判程序的完善，重点在于统一瑕疵出资股东的责任范围。债权人通过执行追加程序所能够主张的债权，不包含股东瑕疵出资额相应的利息，那么，当债权未得到完全清偿时，债权人还能否另行提起侵权诉讼，主张利息范围内的债权呢？

如前所述，执行机构作出的审查判断不具有终局性的效力，如果债权人对瑕疵出资股东申请执行追加仍未获得完全清偿时，不得另行提起诉讼要求股东履行利息范围内的清偿义务，这样的制度安排似乎并不妥当，毕竟执行追加毕竟不是诉讼程序，何以产生既判力，又何以阻却后诉的发生呢？基于此剥夺当事人根本就未获得诉讼程序保护的实体权利上的请求权，有违基本法理，难以自圆其说。因此，在追加瑕疵出资股东、并予以执行后，仍未获得完全清偿的债权人，可以以利息为限诉请股东要求其清偿。

除此以外，因实体法规定的责任范围大于执行追加司法解释的规定，必然进一步引发关于部分请求是否构成重复诉讼的争议，具体而言，经过执行异议之诉后仍未获得完全清偿的债权人能否另行提起侵权民事诉讼，另诉主张利息部分请求权是否会触发重复诉讼规则而予以禁止。

关于能否准予部分请求的问题，目前主要有肯定说与否定说两种观点。肯定说认为实体法只限制了权利的外部边界，在边界内当事人可自由的分割权利，在私法关系上应奉行“法无禁止即为可行”，应充分尊重当事人对债权的处分自由，程序法也应当与实体法保持一致的立场，允许当事人自由的行使主张。否定说则认为，如果在程序上放开部分请求的闸门，必然会给被告带来不必要的诉累，给法院的审理带来不经济和非效率

中国知网 https://www.cnki.net

的负面效应。[90]

张卫平教授持否定说的观点，认为部分请求能否再诉的问题，我国现行法没有明确规定，但是最高法在司法解释中表明了其态度，为司法实践提供了指引。根据最高法《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第 6 条的规定，后诉当事人基于同一侵权事实提起的精神损害赔偿请求，受到前诉法院就其主张的物质损害赔偿请求作出的终局判决的既判力的约束，因此，法院不得受理后诉，否则属于重复诉讼。[91]准予此论，对于债权人另行对瑕疵出资股东提起诉讼，主张未获清偿的利息范围的债权，法院不应受理。

傅郁林教授持肯定观点，其认为中国与德国是少数允许同一诉讼标的下提起部分请求的国家，德国限定为前诉中胜诉者可就剩余部分再诉，败诉者则不得再诉，我国规定也大致与德国相同。从比较法之视野看，目前判断部分请求再诉是否属于重复起诉有三种模式：一是看前诉中是否提起；二是看前诉中是否应该提起而未提起；三是看是否前诉中应该提起，也提起了，但没有进行裁判。我国采取的是看前诉中是否提起，并且是否被裁判过了的判断模式，我国采取的判断模式较之前三种模式更为宽松，因为我国没有实行被告律师强制代理制度，在考虑现实国情的基础上，对于部分请求的能否再诉的问题应采取更为包容的态度。[92]

笔者更赞同后者之观点，毕竟当前执行异议之诉的性质到底为何还尚无定论，其诉讼标的到底为何莫衷一是，执行异议之诉判决既判力的效力范围到底为何也众说纷纭，因此，允许债权人就无法于执行追加异议之诉中获得救济的利息范围内的债权另行提起诉讼，更为妥当可行。

但是，必须强调，统一瑕疵出资股东在执行追加与侵权诉讼中的责任范围才能标本兼治，唯有如此才能避免落入进退失据的尴尬局面，防止实体法赋予的权利落空。

（四）救济程序的规则完善

如前所述，《变更、追加规定》规定的两种救济程序在适用上进入了误区。程序性

[90] 参见张卫平：“重复诉讼规制研究：兼论‘一事不再理’”，《中国法学》，2015 年第 2 期，第 43—65 页。
[91] 参见张卫平：“重复诉讼规制研究：兼论‘一事不再理’”，《中国法学》，2015 年第 2 期，第 43—65 页。
[92] 参见傅郁林：“繁简分流予与程序保障”，《法学研究》，2003 年第 1 期，第 50—63 页。

中国知网 https://www.cnki.net

救济与实体性救济，这两类救济程序均应具有普适性，不论何种事由引起的执行追加，当事人都可以提起程序性救济或实体性救济，仅因其异议内容的不同而启动不同的救济程序。在瑕疵出资股东的执行追加中，执行当事人与被追加的股东除可提起执行异议之诉外，也应准许其提起复议，求诸程序性救济，两种类型的救济制度，并行不悖，应当同时适用于执行当事人变更、追加的所有事由。

赋予瑕疵出资情形下执行追加的各方主体，寻求实体性救济的机会，除涉及实体问题的判断外，更为根本的原因在于瑕疵出资股东受执行名义执行力主观范围扩张所及，但并不在既判力扩张的范围内，换言之，当事人随时可以通过另行寻求审判救济来质疑执行追加中作出的判断，甚至是已得到执行的财产也因审查结果的非终局性而处于动荡中。

为解决上述问题，域外实行执行文制度的国家一般设置前置性的执行文赋予之诉，通过诉讼确定权利义务状态、确保执行结果的安定。我国执行程序中尚不具有执行文赋予之诉，而是在瑕疵出资股东的执行追加程序中确立了实体性执行救济制度，因此必须妥善处理该实体性救济程序与民事诉讼程序的关系。表现在司法实践层面，也就是债权人提起执行异议之诉后，能否再回到普通民事诉讼的路径，另行对可能存在瑕疵出资情形的股东提起股东损害公司债权人利益责任纠纷之诉。

具言之，瑕疵出资股东的执行追加有其特殊之处，因股东的补充责任具有相对的独立性，其责任范围与执行名义确定的执行债权不一致，单独确定瑕疵出资股东是否为适格当事人没有意义，在执行异议之诉中必须同时对责任范围作出判断，当事人也就无权另行针对股东提起侵权诉讼，此处瑕疵出资股东执行追加的救济完全吸收了普通民事诉讼。司法实践中，法院一般也认可在执行异议之诉中一并解决实体争议的做法，执行异议之诉在事实上应吸收普通民事诉讼。[93]

“良好的制度设计促使债权人为了最大限度地保护自己的利益，不可能绕过执行异议之诉而另行针对债务人提起独立的普通民事诉讼，以主张原本应作为执行异议之诉的理由的民事诉讼。”[94]同样，良性的制度设计也不能容忍相同的争议能够一而再的经历诉讼，这有违诉讼经济的价值追求，无端加重了被告的诉讼负担，损害了经判定的权利

[93] 参见江苏省（2016）苏0923执异23号关于执行异议的裁定书，其中明确表明了债权人及被追加的瑕疵出资的股东可以提起执行异议之诉，并在执行异议之诉中一并提起权利确认之诉。

[94] 参见赵秀举：“论民事执行救济 兼论第三人执行异议之诉的悖论与困境”，《中外法学》，2012年第4期，第835—853页。

中国知网 https://www.cnki.net

的安定状态。[95]换言之，作为执行救济的执行异议之诉，其制度初衷在于解决执行中的纠纷，并不负担侵权诉讼的功能，但是其毕竟具有诉讼的性质，这意味执行异议之诉并不拒绝同时解决民事实体争议，如二者呈现紧张的局面，那是制度设计与实践操作层面的问题，与制度的本质无关。[96]

综上所述，执行异议之诉与普通民事诉讼的理想关系，应当是后者在一定程度上被前者所吸收，在追加执行瑕疵出资股东的程序中，当事人提起的执行异议之诉的判定应产生既判力，当事人不得基于同一实体法律关系另行提起普通民事诉讼，但这必须以上述责任范围的统一为前提，且给执行异议之诉的制度设计和具体操作提出了更高的要求，如不对执行异议之诉的性质、诉讼标的、救济机制等方面相应作出调整和完善，吸收普通民事诉讼也只能存在于理想中。

[95] 参见张卫平：“重复诉讼规制研究：兼论‘一事不再理’”，《中国法学》，2015 年第 2 期，第 43—65 页。

[96] 参见赵秀举：“论民事执行救济 兼论第三人执行异议之诉的悖论与困境”，《中外法学》，2012 年第 4 期，第 835—853 页。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、著作类

1. 田平安主编：《民事诉讼法学（第四版）》，北京：法律出版社，2015 年版。

2. 田平安主编：《民事诉讼法原理（第五版）》，厦门：厦门大学出版社，2009 年版。

3. 张卫平著：《民事诉讼法》，北京：法律出版社，2016 年版。

4. [日]新堂幸司著：《新民事诉讼法》，林剑锋译，北京：法律出版社，2008 年版。

5. [日]中村英郎著：《新民事诉讼法讲义》，陈刚等译，北京：法律出版社，2001 年版。

6. 杨与龄编著：《强制执行法论》，北京：中国政法大学出版社，2002 年版。

7. 王亚新著：《社会变革中的民事诉讼》，北京：北京大学出版社，2014 年版。

8. 张卫平著：《诉讼构架与程式》，北京：清华大学出版社，2000 年版。

9. 王泽鉴著：《民法学硕与判例研究（重排合订本）》，北京：北京大学出版社，2015 年版。

10. 王泽鉴著：《民法思维：请求权基础理论体系》，北京：北京大学出版社，2009 年版。

11. 李龙著：《民事诉讼标的理论研究》，北京：法律出版社，2003 年版。

12. 顾培东著：《社会冲突与诉讼机制（第三版）》，北京：法律出版社，2015 年版。

13. [日]谷口安平著：《程序的正义与诉讼（增补本）》，王亚新、刘荣军译，北京：中国政法大学出版社，2002 年版。

14. [德]米夏埃尔等编：《德国民事诉讼法学文萃》，赵秀举译，北京：中国政法大学出版社，2005 年版。

15. 李浩主编：《强制执行法》，厦门：厦门大学出版社，2004 年版。

中国知网 https://www.cnki.net

16. 王亚新著：《对抗与判定——日本民事诉讼的基本结构》，北京：清华大学出版社，2010 年版。

17. 刘俊海著：《公司法学》，北京：北京大学出版社，2009 年版。

18. 李昌麒主编：《经济法学（第四版）》，北京：中国政法大学出版社，2014 年版。

19. 常廷彬著：《民事判决既判力主观范围研究》，北京：中国人民公安大学出版社，2010 年版。

20. 胡军辉著：《民是既判力扩张问题研究》，北京：中国人民公安大学出版社，2011 年版。

21. 刘安著：《中国公司法律制度——政治经济学维度的解读》，北京：北京大学出版社，2017 年版。

22. 荣振华著：《<公司法>立法与司法解释互应影响之研究》，北京：清华大学出版社，2018 年版。

23. 林剑锋著：《民事判决既判力客观范围研究》，厦门：厦门大学出版社，2006 年版。

24. 袁碧华著：《我国公司资本制度改革研究》，北京：中国政法大学出版社，2016 年版。

25. 赵树文著：《公司资本规制制度研究》，北京：人民出版社，2015 年版。

26. 王艳华著：《反思公司债权人保护制度》，北京：法律出版社，2008 年版。

27. 徐东著：《公司治理的司法介入研究》，北京：法律出版社，2016 年版。

28. 杨仁寿著：《法学方法论》，北京：中国政法大学出版社，1999 年版。

29. 马登科：《案外人救济制度研究》，北京：法律出版社，2016 年版。

30. 刘俊海：《现代公司法（第三版）上册》，北京：法律出版社，2015 年版。

31. 崔建远：《合同法》，北京：法律出版社，2016 年版。

二、论文类

32. 张卫平：“判决执行力主体范围的扩张——以实体权利转让与执行权利的获得为中心”，《现代法学》，2007 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

33. 翁晓斌：“论既判力及执行力向第三人的扩张”，《浙江社会科学》，2003 年第 3 期。

34. 陈桂明、范向阳：“不动产执行程序中执行力的扩张——兼论执行法作为程序法对实体法的回应和干预”，《人民司法（应用）》，2007 年第 21 期。

35. 梁上上：“未出资股东对公司债权人的补充赔偿责任”，《中外法学》，2015 年第 3 期。

36. 肖建国：“执行当事人变更与追加的程序研究——基于德、日、韩执行文制度的比较分析”，《法律适用》，2011 年第 9 期。

37. 肖建国：“执行当事人变更与追加的救济制度研究——基于德、日、韩执行文制度的比较研究”，《法律适用》，2013 年第 7 期。

38. 黄忠顺：“论执行当事人变更与追加的理论基础”，《北京科技大学学报（社会科学版）》，2013 年第 2 期。

39. 丁宝同：“民事判决既判力研究”，西南政法大学博士学位论文，2009 年。

40. 丁宝同：“执行异议之诉：比较法视野下的谱系研究”，《比较法研究》，2015 年第 4 期。

41. 谭秋桂：“论民事执行当事人变化的程序构建”，《法学家》，2011 年第 2 期。

42. 常廷彬：“试论执行力主观范围的扩张”，《法治论坛》，2010 年第 1 期。

43. 吴英姿：“代位执行之我见”，《南京大学法律评论》，1998 年秋季号。

44. 吴英姿：“判决效力的对外性及相对性”，《学海》2000 年第 4 期。

45. 高尚民：“《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》的理解和适用”，《人民司法（应用）》，2009 年第 9 期。

46. 潘勇锋：“论瑕疵出资人责任范围——以对公司债权人承担的责任为限”，《北京仲裁》，2013 年第 86 辑。

47. 沈晓明：“股东瑕疵出资情形下权利人之救济”，《海大法律评论》，2016-2017。

48. 向国慧：“论执行力主观范围扩张”，西南政法大学博士学位论文，2014 年。

49. 魏锋：“执行当事人研究——以执行力主观范围扩张为中心”，中国政法大学博士学位论文，2009 年。

50. 富饶：“公司资本诉讼研究”，吉林大学博士学位论文，2017 年。

中国知网 https://www.cnki.net

51. 甘培忠：“论公司资本制度颠覆性改革的环境与逻辑缺陷及制度补救”，《科技与法律》2014 年第 3 期。

52. 刘书星：“我国执行力扩张制度研究”，《法学杂志》，2015 年第 7 期。

53. 肖建国、刘文勇：“论执行力主观范围的扩张及其正当性研究”，《法学论坛》，2016 年第 4 期。

54. 刘学在、王炳乾：“执行当事人之变更、追加的类型化分析”，《政法学刊》，2018 年 4 月。

55. 肖建华：“论判决效力主观范围的扩张”，《比较法研究》，2002 年第 1 期。

56. 张其鉴：“论认缴制下股东补充赔偿责任中的“不能清偿”标准——基于回归公司法立场的分析”，《政治与法律》，2017 年第 3 期。

57. 郭明瑞：“补充责任、相应的补充责任与责任人的追偿权”，《烟台大学学报（哲学社会科学版）》，2011 年第 1 期。

58. 李中原：“论民法上的补充债务”，《法学》，2010 年第 3 期。

59. 张欢、洪宁：“公司资本制度改革后股东追加执行的困境与突破”，《上海政法学院学报（法治论丛）》，2015 年第 6 期。

60. 许金鑫、李美：“追加未届出资期股东为被执行人探析——以完全认缴资本制下股东提前承担出资责任为视角”，《法院改革与民商事审判问题研究》，全国法院第 29 届学术讨论会刊。

61. 洪冬英：“论审执分离的路径选择”，《政治与法律》，2015 年第 12 期。

62. 唐力：“案外人执行异议之诉的完善”，《法学》2014 年第 7 期。

63. 傅郁林：“繁简分流与程序保障”，《法学研究》，2003 年第 1 期。

64. 张卫平、任重：“案外第三人权益程序保障体系研究”，《法律科学（西北政法大学学报）》，2014 年第 6 期。

65. 赵秀举：“论民事执行救济——兼论第三人执行异议之诉的悖论与困境”，《中外法学》，2012 年第 4 期。

66. 章武生、金殿军：“案外人异议之诉研究”，《法学家》2010 年第 5 期。

67. 杨立新：“论不真正连带责任类型体系及规则”，《当代法学》，2012 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

68. 张卫平：“我国民事诉讼法理论的体系建构”，《法商研究》，2018 年第 5 期。

69. 张新宝：“我国侵权责任法中的补充责任”，《法学杂志》，2010 年第 6 期。

70. 庄加园：“初探债权执行程序的理论基础——执行名义欠缺的质疑与收取诉讼的构造尝试”，《现代法学》，2017 年 5 月。

71. 刘文勇：“再探代位执行程序的理论基础——从代位执行的执行依据及其正当性展开”，《民事程序法研究》，第十八辑。

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

行文将毕，然言未尽。在山城雾都的三年研究生时光，打马而过。十分荣幸能够进入到仰慕已久的西政校园，在花香弥漫、鸟语盈耳的校园里学习生活，在课堂里领略智慧的交锋，感悟老师们或敏锐、或博大、或深邃的思想。

回首三年研究生时光，对各位老师的感激之情难以言表。尤其感谢恩师丁宝同老师，丁老师渊博的学识、雄辩的才华，给我带来了广阔的视野、启发我不断的挑战自我；丁老师严谨的治学态度，令我钦佩不已，不断地敦促我勤读书、多思考，鞭策我不断进步，砥砺我前行；丁老师认真负责的工作态度，更是令我羞愧不已，对于我的论文写作，丁老师给予了巨大的帮助，论文每一稿丁老师都仔细阅读，并提出了大量的有针对性的修改建议，在这里衷心感谢丁老师对我的殷殷教诲和倾力帮助！

此外，还要感谢同窗室友们对我论文的指点与启发，感谢她们在这三年里对我的关心与帮助！

中国知网　https://www.cnki.net